

建構量刑階段中罪刑相當原則的第一哩路^{*} —— 自應報觀點形塑刑罰量定之理論嘗試

范耕維^{**}

摘要

罪刑相當原則係指刑罰程度應與犯罪相對應，但何謂相對應則欠缺明確內涵。本文目的即是釐清此內涵，嘗試建構量刑應適用的罪刑相當原則。本文認為量刑本質是在量定刑罰施加於犯罪人之不利益的程度，故罪刑相當原則的意義就在於法官可依循此原則，針對犯罪進行適度的刑罰量定。亦即，罪刑相當原則可理解為比例原則規範意涵在刑罰量定層次的具體適用。在此脈絡下，相當的刑罰量定之判斷基準為何，取決於如何選擇量刑時應依循的刑罰目的。如此一來，罪刑相當原則的概念內容與刑罰哲學中應報主義與效益主義的爭論，有著密切的關係。更具體來說，罪刑相當原則的各理論，都是基於應報主義、效益主義或結合二者觀點所建構而成。本文在我國脈絡下，首先與當代應報理論對話並逐一檢討，接著提出屬於應報觀點的「代價承擔理論」，來作為建構罪刑相當原則的理論基礎。

* 投稿日：2020年5月11日；接受刊登日：2021年7月5日。〔責任校對：李友銓〕。

本文初稿發表於2020年中央研究院法律學研究所個人年度學術研討會。感謝匿名審查人對本文尚不成熟之觀點的指點與批評，使筆者有加以修正並使之完善的方向。會議中李建良、邱文聰、許家馨、張永健、吳宗謀、邵允鍾等研究人員與林榮光博士對本文論點及撰寫方式提供寶貴的意見與建言，使筆者得以使論述與文章架構更為嚴謹完整，特此致謝。薛熙平博士、陳冠廷先生、羅浩瑋先生針對本文閱讀後，與筆者的討論中所提出的批評指教，亦令筆者獲益匪淺，十分感激。至於一切文責，則由筆者個人自負。

** 國立東華大學法律學系助理教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/91511022.pdf>。



關鍵詞：刑罰哲學、量刑理論、罪刑相當原則、應報主義、效益主義、嚴厲處遇、單純應得理論、公平遊戲理論、混合理論、溝通應報理論。

目次

壹、前言	二、單純應得模式
貳、量刑相當原則的建構取徑	三、公平分配模式
一、從刑罰本質解析量刑相當原則之建構	四、表現與溝通模式
二、刑罰哲學之建構取徑	肆、本文立場之建構
三、量刑相當理論與我國發展現況	一、本文立場之發展路徑
四、理論建構之核心課題	二、嚴厲處遇內涵之詮釋
參、當代應報理論之對話與檢討	三、量刑相當原則與量刑責任之建構
一、應報理論之選擇基準與對話方式	伍、結論

壹、前言

2019年迄今，大法官於司法院釋字第775號、第777號與第790號解釋中，皆宣稱其透過「罪刑相當原則」之概念來檢視刑罰規範的合憲性。同時，以最高法院109年度台上字第2323號刑事判決為例，當檢視我國法院判決的科刑部分時，法官也多提及刑事審判目的為實現刑罰權的分配正義，據此要求科刑應輕重得宜、罰當其罪，以符合罪刑相當原則之要求¹。由此觀之，我國現況下無論是

¹ 我國實務採相同論述者眾，如最高法院108年度台上字第3166號刑事判決提及：「刑事審判之量刑，旨在實現刑罰權之分配正義，並與犯罪情節有關。故法院對有罪之被告科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜、罰當其罪」。

刑罰規範或個案科刑，皆受到罪刑相當原則之約束。不過，雖此原則在我國實務已具重要性，惟若檢視大法官解釋或法院判決時，多僅宣稱適用該原則，卻未詳細說明其內涵。誠然，關於此原則之內涵，我們或可在學理上找到多數論者皆有共識且與上開判決中「輕重得宜、罰當其罪」相近的定義：刑罰應與犯罪相當，二者應處於合比例（proportionality）的關係²。但是，究竟如何理解刑罰與犯罪間「合比例」的實質內涵，依然是尚待釐清的問題。而本文目標就在於嘗試釐清罪刑相當原則之概念內涵、考量要素與判準。

不過，考慮到刑罰結果的產生，實際上歷經立法者針對特定犯罪類型制定法定的刑罰規範與依靠法官考量個案情節來量定輕重等階段³，則適用於不同階段之罪刑相當原則內涵可能會有所差異。首先，雖然大法官解釋與法官科刑皆提及罪刑相當原則之適用，但考量到大法官違憲審查目前是以刑罰規範為對象，而法官科刑是針對個案量刑，當罪刑相當原則中的「刑罰」一詞可指涉的層次，包括「刑罰規範」與「個案量刑」時，不同層次適用之罪刑相當原則內涵即可能存在差異。接著，依照我國現況，除大法官會在違憲審查階段以刑罰規範為對象，適用「憲法罪刑相當原則」來審查其合憲性外，立法者也會針對特定犯罪進行抽象非難評價而在刑法分則中制定法定本刑之規範，以及類型化出可加重與減輕刑罰的抽象因子，而在刑法總則中制定處斷刑之規範⁴，故有在立法時制定罪刑

此外，如最高法院109年度台上字第5414號刑事判決也指出：「刑之量定，屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項……無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，亦無偏執一端，致明顯失出入情形，自不得指為違法」，表明量刑時遵守罪刑相當原則為科刑合法之要件。

2 Richard S. Frase, *Theories of Proportionality and Desert*, in THE OXFORD HANDBOOK OF SENTENCING AND CORRECTIONS 131, 131 (Joan Petersilia & Kevin R. Reitz eds., 2012).

3 蘇俊雄，刑法總論III，2版，頁390（2000年）；川崎一夫，体系的量刑論，頁36（1991年）。

4 如果犯此種基於刑罰目的與刑事政策需求，賦予法官加重、減輕或免除法定刑之權限的規定，被稱為「處斷刑」。參見蘇俊雄（註3），頁390。

相當之刑罰規範的必要。同時，不同於此二階段，法官則是在法定規範之範圍內，考量行為人個案犯罪行為中，可歸類於抽象的罪名及加重、減輕事由的具體因子，適用刑法第57條等規定來進行量刑⁵。由此觀之，除了刑罰規範與個案量刑的層次差異外，由於在違憲審查、立法與法官科刑等階段中，會基於各自不同目的來判定規範是否符合罪刑相當之要求或量定罪刑相當之刑罰，故對應於階段間之差異，罪刑相當原則的內涵可能也有所不同⁶。

在此狀況下，考量篇幅限制，基於下述兩項理由，本文將先以建構法官科刑階段適用之罪刑相當原則為重心。此外，為求行文方便，並考量科刑階段所追求的是法官量定與犯罪相當之刑罰，故以下皆將適用於此階段的罪刑相當原則，簡稱為「量刑相當原則」。理由一，雖然立法者是依據其所想像之抽象的犯罪類型圖像，來制定與之相當的刑罰規範。但立法者所構想之圖像，無可避免是以過往侵害該種法益的實際事例為基礎，由各事例之犯行歸納而成。誠然，立法者與法官對犯罪事實相關要素的考量面向與考量時的抽象、具體程度有別，但當立法者以犯罪主客觀層面的各種事實要素作為評價對象，來嘗試形塑符合罪刑相當的法定刑時，過往法官在個案中同樣以這些事實要素為基礎，所量定出符合量刑相當之刑罰效果，即可能作為參考依據，也突顯討論量刑相當之實益。理由二，雖然前述三則大法官解釋是在違憲審查階段以刑罰規範之罪刑

5 參見最高法院109年度台上字第2874號刑事判決：「『刑罰之制定』，乃立法者針對特定犯罪所為基本之抽象非難評價，呈現為刑法分則所明文特定罪名之『法定本刑』。而『刑罰之加減』，係立法者透過在刑法總則規定類型化之絕對或相對之刑罰加重與減輕事由，而就特定罪名對司法者為量刑框限之變動指示，展現於學理名為『處斷刑』之刑罰調整，以上皆屬立法者之刑罰制定。至『刑罰之適用』，則屬司法者之刑罰裁量，體現於法院就特定行為人所犯特定罪名，於法律規定範圍內所為之個案量刑」。學說有以累犯為例的相同看法：許恒達，累犯與處斷刑加重之裁量：評大法官釋字第775號解釋暨後續實務裁判，月旦法學雜誌，294期，頁8（2019年）。

6 周漾沂，刑罰的自我目的性——重新證立絕對刑罰理論，政大法學評論，147期，頁319（2016年）。

相當為審查對象，看似與法官個案量刑無關。但是，一方面，各解釋之聲請皆源自法官個案量刑層次中，遭遇無法量定與犯罪相當刑罰的疑慮。另一方面，以司法院釋字第775號與第790號解釋來說，大法官宣告相關規範違憲的同時，也都表示由法官依解釋意旨考量個案情節來裁量相當之刑罰⁷。由此觀之，量刑相當與否之判斷，實則與對刑罰規範之違憲審查間存在密切關聯，而在憲法訴訟新制上路且可對個案聲請釋憲後，量刑相當原則之建構與如何將其運用於憲法層次將更顯重要，也突顯先釐清此概念之必要。

以下，筆者即以法官量定與個案中犯罪行為相對應之宣告刑時，應適用並作為刑法第57條等量刑相關規範之解釋基礎的量刑相當原則，作為本文討論的核心⁸。首先，本文以釐清刑罰的本質為起點，嘗試指出推導量刑相當原則時，必須回應的具體問題，並說明採取從量刑目的來回應這些問題的推論視角。同時，筆者將指出

7 司法院釋字第775號解釋提及「於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑」，而司法院釋字第790號解釋理由書提及「逾期未修正，其情節輕微者，法院得依本解釋意旨減輕其法定刑至二分之一。其情狀顯可憫恕者，仍得另依刑法第59條規定酌減其刑」。對司法院釋字第775號解釋後實務運作之觀察，參見謝煜偉，當弦外之音成為主旋律——評釋字第775號解釋兼論解釋公布後之量刑新趨勢，月旦法學雜誌，294期，頁38-45（2019年）。

8 法官決定個案刑罰輕重可分為宣告刑與執行刑：前者指法官對具體犯罪行為，依法定刑之規定，於其種類與範圍中選定刑罰具體形式與科處程度，對犯罪人所為科處宣告之刑罰；後者指以前者為基礎，法院具體宣告而犯罪人必須確實執行之刑罰，具有刑罰具體實現的作用（孫啟強，定應執行刑逾二年可否宣告緩刑，司法周刊，1981期，2版（2019年））。依最高法院見解（如最高法院108年度台聲字第226號刑事裁定、106年度台抗字第191號刑事裁定），不同於宣告刑是依刑法第57條來對犯行進行裁量，定應執行刑是總檢視犯罪人之人格及所犯各罪間的整體關係後所為特別量刑過程，故應考量犯罪人所犯數罪反應出之人格特性，並應權衡行為人責任與整體刑法目的及相關刑事政策、審酌回復社會規範秩序之要求，受刑法第51條第5款的自由裁量權之外部界限，以及比例原則、平等原則、罪罰相當原則及重複評價禁止原則等自由裁量權的內部抽象價值要求界限所支配。既然二者有判斷上先後關係且基於不同考量來分別量定，則二階段中如何量定相當之刑，即應分別討論。由於執行刑係以針對各獨立犯行進行量定之宣告刑為基礎，且本文重心放在量刑與犯行相對應之討論，故即先以宣告刑為討論重心。

在我國目前理論發展的脈絡下，本文將嘗試從應報觀點來進行量刑相當原則內涵之建構，進而補充目前我國理論發展的不足（本文「貳」）。接著，在當代應報理論具有多樣化內涵的狀況下，筆者將先說明本文對應報觀點的選擇基準，並依序針對當代各應報理論進行分析與檢討（本文「參」）。最終，筆者會嘗試說明所理解之應報與量刑相當原則概念內涵，並由該內涵來具體形塑出刑法第57條中作為量刑基礎的行為人之責任，亦即「量刑責任」的概念意涵（本文「肆」）。

貳、量刑相當原則的建構取徑

本文以釐清法官個案中應如何量定與犯罪相當之刑罰作為關照的重心，故在釐清處理的問題層次時，若借用H.L.A. Hart關於刑罰所提出的三個問題層次：1. 定義問題（刑罰是什麼）、2. 一般性的正當目的之問題（如何正當化一般性的刑罰實踐）、3. 分配問題（何者應被刑罰所適用、刑罰的程度為何）⁹，自然是以第三層次，也就是刑罰實踐中對具體個案所為之刑罰量定，作為討論重心。亦即，關於量刑相當原則內涵之討論，係以何謂與具體個案相對應之刑罰量定作為討論主軸。若是如此，當我們要更細緻地充實量刑相當原則之內涵時，勢必要深入地追問「刑罰量定的內涵為何」，亦即量刑究竟是要量定什麼內容、其是指稱何種態樣與內容之量度及決定¹⁰。

9 H.L.A. HART, PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY: ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF LAW 3-4 (2d ed. 2008).

10 事實上，以最高法院107年度台非字第82號刑事判決提及的「刑事審判旨在實現刑罰分配之正義，故事實審法院對被告之量刑應符合比例、平等及罪刑相當原則」為例，我國法院多將量刑或刑罰量定稱為「刑罰分配」。但是，考量到刑罰是在施加不利益於犯罪人，與典型分配對象為利益有所不同，故本文將避免使用刑罰分配一詞。不過，在當代應報理論中，也不乏存在如後面會提到的

對此，本文認為必須由刑罰本質談起，先釐清刑罰是由哪些要素所組成，才能更清楚地解構「刑罰量定」此概念，指出針對個案為刑罰量定時，各要素的相互關係以及與刑罰量定最相關之要素為何。如此一來，我們才能根本地完成量刑相當原則的建構工作。以下，筆者先著眼於刑罰本質，並分析刑罰之組成要素，指出從這些要素中理解刑罰量定的意涵後，必須清楚回應哪些具體問題，才能完整地建構量刑相當原則之內涵。接著，筆者會指出要透過何種理論建構取徑，來回應這些細部問題與充實量刑相當原則之內涵。最終，依循本文選擇的建構取徑，筆者將以我國量刑理論發展現況為基礎，指出本文將從應報觀點來建構量刑相當原則之嘗試。

一、從刑罰本質解析量刑相當原則之建構

關於刑罰的本質，無論是國內文獻如王皇玉將其描述為一種對應犯罪而來的法律效果，由國家用強制力施加對犯罪人生命、自由或財產之侵害的方式來進行¹¹，或如刑罰哲學領域所普遍引用的Hart定義：「被違法行為所侵犯的法律系統所設置之有權機關，對於確實違反法規範或可能違反者，以違反該法規範之行為為由，有意圖地對其施加或執行痛苦（pain）或其他一般來說令人不快（unpleasant）之結果」¹²，皆將懲罰描述為由有權施加與執行者，透過施加痛苦或使人不快的效果為手段，基於懲罰意圖來對違反法規範之行為進行回應。由於本文是在我國脈絡下進行討論，考量我國採國家訴追原則而由國家獨占刑罰權¹³，且刑法是透過對犯罪人加諸生命、自由與財產等利益之限制，以施加對犯罪人之不利益、

公平分配模式，係採取將刑罰的內容由不利益的施加轉換為不公平利益的衡平，進而透過分配正義觀點來建構理論之嘗試。因此，在論述此模式的理論嘗試時，本文會配合理論脈絡而使用刑罰分配一語，在此敘明之。

11 王皇玉，論刑罰的目的，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁3（2009年）。

12 HART, *supra* note 9, at 4-5.

13 林鈺雄，刑事訴訟法（上冊），8版，頁44-45（2017年）。

損害(harm)來造成痛苦或不快之具體效果¹⁴，故初步將刑罰本質理解為：由國家基於懲罰意圖，為回應已發生的犯罪，對犯罪人施加不利益之結果。

不過，若由刑罰作為違反刑法之法律效果的面向來看，或可發現刑罰未必僅是針對犯罪人施加不利益。申言之，當刑法以保護法益為其目的時，刑法內容自然包括宣示人們不應實行某種犯罪行為之禁止規範¹⁵。同時，由於單憑行為規範禁止人們做特定行為是不夠的，故勢必需要規範與被禁止行為相對應之刑罰效果，亦即所謂的制裁規範。如此一來，我們可以說刑罰在本質上包括對違反禁止規範之犯罪行為的回應。而當作為回應對象的犯罪內涵是對法益的侵害時，則犯罪必然造成對刑法上值得保護之他人權利、利益或社會秩序的侵害，而在刑法規範的評價下具有否定性意涵。那麼，刑罰作為對犯罪之反作用力施加與對應時¹⁶，自可能內含對犯行的否定意涵。此外，當刑法中犯罪係指不法且有責之行為時¹⁷，刑罰本質也必然與這些犯罪成立要件之意涵相呼應。亦即，若犯罪階層中「有責性」是以犯罪人有無他行為可能性為判斷基礎的非難可能性作為概念核心¹⁸，則當刑罰是對此種犯罪行為之對應時，可謂刑罰僅能對行為具可非難性的犯罪人發動。如此一來，或可將刑罰本質理解為不僅是對犯罪人施加不利益，同時還包括對其傳遞否定犯罪行為之非難訊息（下稱：非難傳遞）¹⁹。刑罰理論的討論中，如

14 相似用語，*see* DAVID BOONIN, *THE PROBLEM OF PUNISHMENT* 6-7 (2008).

15 王皇玉，*刑法總則*，6版，頁5（2020年）。

16 吉岡一男，*刑事學*，新版，頁24（1996年）。

17 王皇玉（註15），頁120；黃榮堅，*基礎刑法學（上冊）*，4版，頁169（2012年）。

18 王皇玉（註15），頁321。

19 在此僅指出作為刑事制裁的刑罰，其本質上存在非難傳遞之要素，但並未否定行政罰等其他制裁形式中同樣存在該要素之可能。事實上，行政罰甚至民事制裁都有詮釋為具懲罰性質而帶有該要素之可能。話雖如此，由於刑罰是針對犯罪施加之制裁，故與以損害為對象之民事侵權法及以未必構成犯罪之規則違反為對象之行政罰間，仍存在制裁對象的差異。接著，不同於行政罰由行政機關

Joel Feinberg將刑罰理解為「為了對犯罪人表達憎惡（resentment）與憤慨（indignation）的態度，以及反對（disapproval）與非難（reprobation）之判斷的傳統裝置（conventional device）」²⁰，即是在刑罰係對他人權利侵害之前提下，肯定刑罰本質包括非難傳遞的立場。另外如Carol S. Steiker也強調刑罰作為一種對他人的譴責（blaming），亦即以公開方式將對犯罪的反對傳遞於他人的非難行為²¹，同樣是肯定刑罰本質包括非難傳遞的看法。

綜上所述，本文將刑罰理解為「由國家基於懲罰的意圖，為回應已發生的犯罪，對犯罪人傳遞非難並施加不利益之結果」，亦即刑罰本質上可謂由「非難傳遞」與「不利益之施加」等要素所組成²²。在此理解下，當法官進行個案量刑，亦即對個案為刑罰量定時，既然是在科以自由刑剝奪人身自由、罰金刑剝奪財產等選項中，選擇要施加何種類與何程度之刑罰於犯罪人，故可謂刑罰量定即是在不利益施加的層次，或刑罰哲學脈絡下稱為「嚴厲處遇（hard treatment）」的層次中²³，量度並決定要施加什麼形式與程度

發動即可，基於「無刑事程序則無刑罰」（白取祐司，刑事訴訟法，8版，頁1（2015年））的思維，刑罰必須經審判程序後由司法權來發動，也可發現不同制裁方式在決定過程上的差異。另外，我國學說也有主張刑罰與行政罰間存在嚴厲程度上的差異（王皇玉（註15），頁5）。如此一來，雖然不同法領域的制裁可謂皆有傳遞非難之要素，但基於前述差異，各種制裁在本質要素的內涵上或應有所區別。不過，基於本文係以刑罰為討論對象，且考量行政罰之非難傳遞可能涉及擬制主體（法人）的對象差異，若納入討論勢必更為繁雜，非本文篇幅所能處理，故暫且不論。

20 Joel Feinberg, *The Expressive Function of Punishment*, in *DOING AND DESERVING: ESSAYS IN THE THEORY OF RESPONSIBILITY* 95, 98 (1970).

21 Carol S. Steiker, *Punishment and Procedure: Punishment Theory and the Criminal-Civil Procedural Divide*, 85 *GEO. L.J.* 775, 804 (1997).

22 相似觀察，see Klaus Günther, *Criminal Law, Crime and Punishment as Communication*, in *LIBERAL CRIMINAL THEORY: ESSAYS FOR ANDREAS VON HIRSCH* 123, 126 (AP Simester, Antje du Bois-Pedain & Ulfrid Neumann eds., 2014). 國內指出刑罰具此二要素者：李茂生，量刑因子的調查與辯論，法官協會雜誌，15卷，頁107-108（2013年）。

23 R. ANTONY DUFF, *PUNISHMENT, COMMUNICATION, AND COMMUNITY* 29 (2001). 國內採此概念：許家馨，應報即復仇？——當代應報理論及其對死刑之意涵初探，

的不利益於犯罪人。不過，刑罰本質中除對犯罪人之嚴厲處遇外，還包括對犯罪人傳遞非難訊息之部分，亦即刑罰量定其實是在非難傳遞與嚴厲處遇二者的相互關係下，進行不利益形式的決定與程度的量度。如此一來，當要詮釋對個案為刑罰量定之意涵時，即應先著眼於如何理解非難傳遞與嚴厲處遇二者的相互關係，並以對該關係的理解為基礎，來釐清嚴厲處遇的內涵。

申言之，基於上述關於刑罰量定之說明，當我們要建構量刑相當原則之內涵，亦即建構與個案相對應之合比例刑罰量定的意涵時，其實就是要探討何謂合比例地量定嚴厲處遇所施加之不利益。而要說明何謂合比例地量定嚴厲處遇施加的不利益時，核心問題就是應如何理解嚴厲處遇在刑罰中所扮演之角色，進而說明合比例的嚴厲處遇所指涉之意涵為何。不過，由於嚴厲處遇是在與非難傳遞間的關係下運作，故如何理解刑罰量定中嚴厲處遇與非難傳遞的相互關係，自然是我們嘗試釐清合比例嚴厲處遇之意涵時，必須一併回應的問題。綜上所述，若本文要建構量刑相當原則的內涵，更細緻地來說是以回應二個具體問題為基礎：問題一，如何理解非難傳遞與嚴厲處遇間的關係；問題二，以問題一的理解為基礎，合比例之嚴厲處遇的內涵為何。在確定建構量刑相當原則須回應的二個問題後，接著的重點是要從何種視角來加以回應。對此，以下將說明本文欲採取的量刑相當原則建構途徑。

二、刑罰哲學之建構取徑

在量刑相當原則是以法官如何針對個案量定與犯罪合比例之刑罰的前提下，此原則可說是一座橋樑，搭建在關注刑罰制度存立正當性的哲學思辨，與聚焦在刑罰制度如何於刑罰量定中實踐的刑事政策討論之間，將關於刑罰量定哲學基礎的思考，連結至量刑相關

中研院法學期刊，15期，頁254（2014年）。另有譯為「嚴正處遇」者：李茂生，應報、死刑與嚴罰的心理，中研院法學期刊，17期，頁298註2（2015年）。

法規範的具體解釋，消弭二條討論脈絡間的隔閡²⁴。根據該原則之特質，本文將嘗試取徑於刑罰哲學、刑罰理論（philosophy/theory of punishment）的視角，建構法官在理論面上可引以為據來量定與犯罪相當之刑罰的原則。

首先，刑罰哲學是在思考如何證立刑罰作為一般性制度或社會實踐，並進一步討論特定類型刑罰是否應被涵攝在此規則或社會實踐下、應如何證立該特定類型之刑罰等問題²⁵。由於本文討論的量刑可謂是法官透過裁量特定程度的刑罰，將一般性刑罰制度具體實踐於個案刑罰量定中，而量刑相當原則就是討論如何裁量、決定刑罰程度方屬正當，並據此證立特定程度之刑罰，故刑罰哲學可謂是適宜切入討論的取徑。詳言之，由於量刑作為刑罰制度具體實踐，勢必與討論各刑罰目的內涵並加以比較思辨的刑罰理論間存在密切關係，故本文會由證立刑罰正當性的各種刑罰目的之思辨切入，嘗試建構法官決定刑罰程度之量刑相當原則的哲學基礎與概念內涵²⁶。只不過，考量本文討論的是個案量刑層次，故以刑罰理論所提出的刑罰目的作為建構量刑相當原則的基礎時，必須再考量個案量刑的特點，進而思辨適於作為此原則建構基礎的刑罰目的（下稱：量刑目的）為何。

接著，除量刑相當原則與刑罰目的之哲學思辨相關外，上述建構途徑同時也契合於量刑相當原則作為比例原則具體適用之性質。誠然，憲法與刑法的理路仍有所別：一方面，前者旨在保護基本權，而後者係作為公權力對基本權的限制規定²⁷；另一方面，在適

24 Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much?"*, 25 ISR. L. REV. 549, 580 (1991).

25 許家馨（註23）頁209。

26 國內有稱之「刑罰目的觀考量原則」：林山田，*刑法通論*（下冊），10版，頁519（2008年）。

27 李建良，*正當防衛、比例原則與特別犧牲——刑法與憲法的思維方法與理路比較*，*月旦法學雜誌*，291期，頁46-47（2019年）。

用對象上，比例原則應用於憲法層次的法規範違憲審查時，是對既存規範進行審查，而運用在量刑時，則是提供法官追求合比例刑罰量定結果的判準。但是，若比例原則所蘊含的是「適度」的規範意旨²⁸，而自「刑罰應與犯罪相當，處於合比例關係」的定義觀之，量刑相當原則正是在追求適度的刑罰程度時，或有將此原則理解為比例原則在刑罰量定層次之運用的可能。此時，若將「適度」理解為「手段與目的間存在合比例之關係」，且將刑罰本質中之嚴厲處遇理解為限制犯罪人基本權，進而將決定嚴厲處遇程度的量刑詮釋為限制基本權的手段時，則量刑合比例與否，實則取決於個案量刑所欲達成之量刑目的為何。換言之，從比例原則的角度來看，量刑相當原則之建構，可說是以刑罰量定欲達成的量刑目的為基礎²⁹，透過所選擇之目的來詮釋量刑階段中嚴厲處遇之內涵及其與非難傳遞之相互關係，進而推導出適度、相當的刑罰量定的意涵。在此理解下，透過刑罰哲學的取徑，由量刑目的來切入量刑相當原則建構，可謂與該原則本質契合之適當作法。

如上述，此理論建構取徑的操作是先決定刑罰量定所要達成的量刑目的為何，再由該目的推導出與犯罪間合比例之刑罰量定的意涵，進而建構量刑相當原則。詳言之，當選定某量刑目的來證立刑罰的量定時，量刑的程度必須是能達成該目的而具有有效性之程度，但同時也被限定在能達成該目的之程度範圍內：一方面量刑目的會證立一定的刑罰程度，以確立刑度調整起點或加重刑罰的形式反映於刑罰量定中；另一方面量刑目的也會限制刑罰程度不得超過特定範圍，以減輕刑罰或不允許再升高刑罰的形式反映於刑罰量定。而當不同量刑目的各自擁有證立及限定刑罰量定於一定輕重程度的功能時，量刑相當原則之內涵建構的討論重點，就在於對法官而言，用來充實嚴厲處遇與非難傳遞之內涵與詮釋二者關係，進而推導出

28 李建良（註27），頁35。

29 Richard S. Frase, *Punishment Purposes*, 58 STAN. L. REV. 67, 67 (2005).

合比例刑罰程度之要求的量刑目的為何。舉例來說，刑罰目的大略分為應報主義（*retributivism*）與效益主義（*utilitarianism*）：前者立於回顧視角，以如何對應先前已發生的犯罪為關照重心，並認為對應於犯罪而可評價為應得之刑罰，其內在即是正義的³⁰；後者立於展望視角，透過對有益於社會的特定目的之追求來正當化刑罰³¹。因此，選擇量刑目的時就必須思考刑罰量定要追求的只是單純傳遞對應於犯罪之非難及不利益於犯罪人，抑或是追求預防犯罪、防止再犯等利益，又或者是綜合二者。假若以追求防止再犯為量刑目的時，量刑是否相當的判斷標準就是刑罰輕重能否達成該目的，故量刑程度應由未來預防犯罪的有效性所證立與限制³²，僅在能有效達成該效果的範圍內量定刑罰³³。此外，假若認為刑罰量定應綜合數個量刑目的為基礎時，則要在刑度高低的衡量與拉扯中，調和出能得到最適度刑罰量定時，各目的間之相互關係。例如，若認為合比例的刑罰量定，同時以應報與犯罪預防為目的時，各目的之意涵與各目的在量刑過程中之判斷順位與相互關係，都是須釐清的重點。

綜上所述，本文係由量刑目的之選擇切入量刑相當原則之建構，透過該目的來解釋嚴厲處遇之意涵及其與非難傳遞間之關係，進而確立合比例刑罰量定之內涵。如此一來，下一個問題就是應選擇何種目的及如何詮釋該目的之內涵，來作為理論建構之基礎。以下，由於本文目標為建構適用於我國之量刑相當原則，故即以我國量刑理論之發展為對話對象，透過指出目前我國學說理論普遍採取之量刑目的，以及當前論述的不足之處，嘗試說明本文要在何種目的下以何種推論方式來建構量刑相當原則。

30 高橋直哉，刑法基礎理論の可能性，頁152-153（2018年）。

31 DUFF, *supra* note 23, at 13-14, 19.

32 Frase, *supra* note 29, at 69-70; 周漾沂（註6），頁319。

33 Frase, *supra* note 29, at 72.

三、量刑相當理論與我國發展現況

以下先簡述量刑相當原則之理論分類，再透過爬梳我國理論發展現況，指出我國理論發展係以應報為主軸。接著，本文將確立以應報為量刑目的來建構該原則，並揭示形塑應報觀點下之量刑相當原則時，必須依序回應之問題。

(一) 量刑相當理論概述

目前關於量刑目的之論辯，同樣是環繞應報主義與效益主義之對弈所構成：刑罰輕重的量定究竟是取決於對預防犯罪效益的追求，抑或是犯罪人就其犯行應得之懲罰程度³⁴。以Richard S. Frase的分類為例，對應於二者的區別，其將量刑相當原則區別為基於應報思想的「應報的相當 (Retributive Proportionality)」與著眼於犯罪預防的「非應報的相當 (Nonretributive Proportionality)」兩大類^{35、36}。

「應報的相當」是以應報為量刑目的之量刑理論，也被稱為「絕對應報論」。此立場在思考刑罰量定時，並不會考量刑罰未來可能帶來的實際效果，而是聚焦於犯罪人過去的犯罪來決定刑罰程度。換言之，採此觀點的理論認為，合理的刑罰量定是對過往犯罪之回應，故量刑相當指的是刑罰量定應與過去犯行嚴重性間呈現合比例、相當的關係。詳言之，根據此觀點，量刑時應透過綜合「犯罪造成侵害或危險的嚴重程度」與「犯罪人對犯行之可責性 (culpability)」等要素所判定出的「犯行可非難性 (blameworthiness)」，來測定刑罰程度³⁷。因此，可以說持此立場的共同特徵，就在於皆以「刑罰

34 ANDREW VON HIRSCH & ANDREW ASHWORTH, PROPORTIONATE SENTENCING: EXPLORING THE PRINCIPLES 12 (2005).

35 Frase, *supra* note 2, at 131.

36 此分類可對應於國內文獻中的「絕對理論」與「相對理論」(王皇玉(註15)，頁611)。由於從「絕對」、「相對」等文字難以辨識理論內容，故本文借用較可一望即知理論內容的名稱。

37 Frase, *supra* note 2, at 133.

嚴厲程度應與犯罪行為可非難性間相當」作為量刑相當原則的核心內涵。而此核心內涵，即是國內文獻所稱之「罪刑均衡」³⁸，以下本文也使用此詞彙來表述此內涵。不過，應注意到此特徵僅是形式上的描述，由於應報概念內涵相當多元，故根據對應報內涵的不同理解，納入犯罪行為可非難性判斷中的要素也會有所區別，進而導致不同理論對「罪刑均衡」在實質上產生不同理解。

至於「非應報的相當」則是基於效益主義式的思考，認為當量刑目的是追求未來犯罪預防之利益時，量刑相當係指刑罰量定應相當於該利益之追求，同時依據該利益追求來限定刑罰量定之範圍。由於採取目的論式（teleology）的觀點，透過追求社會安全、再犯防止等未來可能的利益來證立刑罰量定，並要求刑罰程度須對應於這些利益之追求，故此理論也被稱為「目的刑理論」³⁹。目前，持此觀點之理論可再依犯罪預防對象為公眾或個人，區分為二類⁴⁰。第一種是以公眾為對象，量刑目的在於防止潛在犯罪人為犯罪行為之一般預防理論。其可再分為透過嚇阻來預防犯罪的消極一般預防理論，以及透過維持與強化公眾對法秩序之信賴與規範意識來預防犯罪的積極一般預防理論⁴¹。前者可溯源自Ludwig Feuerbach的心理強制理論（psychological compulsion），其主張犯罪來自特定慾望與動機，對於特定犯罪施加大於透過該犯罪可得利益之痛苦的刑罰，可壓制潛在犯罪人的慾望與動機，使之放棄犯罪⁴²。而後者是

38 林山田（註26），頁416；謝煜偉，重新檢視死刑的應報意義，中研院法學期刊，15期，頁150-151（2014年）。

39 佐伯仁志，刑法總論の考え方・楽しみ方，頁5（2013年）。

40 王皇玉（註11），頁10-11；Frase, *supra* note 29, at 70.

41 松宮孝明，量刑に対する責任、危険性および予防の意味，收於：ヴォルフガング・フリッシュ、岡上雅美、淺田和茂編，量刑法の基本問題——量刑理論と量刑実務との対話，頁42（2011年）。

42 KAI AMBOS, R. ANTONY DUFF, JULIAN ROBERTS, THOMAS WEIGEND & ALEXANDER HEINZE EDS., CORE CONCEPTS IN CRIMINAL LAW AND CRIMINAL JUSTICE VOL. 1: ANGLO-GERMAN DIALOGUES 226 (2020).

將前者主張的「消極地嚇阻」代換為「積極地確證、強化規範意識」，來追求相同的犯罪預防效果⁴³。若採取積極一般預防作為量刑目的時，則刑罰輕重即應對應於可達成預防潛在犯罪人為犯罪行為之效果的程度，亦即以該刑罰程度是否可促成未來規範意識、法和平性之回復與預防公眾犯罪之效益，作為判斷量刑相當與否的基準。同時，由量刑相當原則形塑之量刑責任，也不僅以侵害法益之行為責任為其內涵，尚應將犯罪行為對法和平性與公眾規範意識的動搖影響納入考量，由公眾法規範意識可否回復來決定行為人之責任⁴⁴。第二種是以個人為對象，量刑目的在於透過抑制或教育等方式來防止犯罪人再犯之特別預防理論⁴⁵。其可再分為以刑罰教化犯罪人，使之再社會化或自新，進而回歸社會且預防再犯的積極特別預防理論，與透過施加痛苦來避免犯罪人再犯或透過隔離犯罪人使之無害化的消極特別預防理論⁴⁶。以前者為例，由於是以回復犯罪人規範意識來防止再犯為量刑目的，故合比例的量刑係指可使犯罪人回復規範意識的刑罰程度，亦即以刑罰輕重可否防止犯罪人再犯，作為量刑相當與否的判斷基準。

不過，正如Hart提到許多自稱應報主義者認為對於犯罪最適宜的對應方式，就是對刑罰程度設定上限，在該限度內考量犯罪人或其他人的再犯預防後選擇刑罰⁴⁷。在應報的相當理論中可見所謂混

43 飯島暢，最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開，香川法学，26卷3・4号，頁334（2007年）。

44 Claus Roxin, Strafzumessung im Lichte der Strafzwecke, in: Walder/Trechsel (Hrsg.), Lebendiges Strafrecht: Festgabe zum 65. Geburtstag von Hans Schultz, 1977, S. 463 (466 ff.).

45 Tatjana Hörnle, Straftheorien, 2. Aufl., 2017, S. 22; 中村悠人，刑罰目的論と刑罰の正当化根拠論，現代法学：東京経済大学現代法学会誌，28卷，頁180（2015年）。

46 城下裕二，特別予防論の現在と責任論の展望，法律時報，88卷7号，頁15（2016年）。

47 HART, *supra* note 9, at 237.

合理論 (Hybrid Proportionality Theories)⁴⁸，亦即國內文獻提及的「綜合理論」⁴⁹，其特徵為允許在應報觀點所形成的框架內考量刑罰可能帶來的犯罪預防效益後，決定刑罰輕重⁵⁰。不過，基於對應報內涵與機能之理解差異，綜合理論又可分為二類⁵¹：第一種是「應報為主、犯罪預防為輔」的「相對應報論」，或有稱為「應報的綜合理論」，雖然以應報主義為基礎思想，但在量刑時仍重視犯罪預防，必須在對犯罪預防來說必要的範圍內科處刑罰；第二種是「預防的綜合理論」，雖然以犯罪預防為量刑基礎，但為避免導致過重刑罰，故基於應報面向，要求以與犯行可非難性相對應的刑罰程度為上限，僅可在該範圍內科刑⁵²。簡言之，第一類型中的應報思想被理解為正當化刑罰量定的根據，故要求應基於應報觀點量刑，如在日本居於通說地位之「幅的理論」，即可歸類為此類型⁵³；而在第二類型中，應報並非賦予刑罰量定正當性的依據，而僅有防止過度追求犯罪預防效益的限定機能，故依應報觀點建構之量刑責任，僅有作為刑罰量定上限之功能。

(二) 我國理論發展現況與問題

接下來，我們轉向對我國理論發展的觀察。以現況來說，雖有應報的綜合理論與絕對應報理論間的路線差異，但可謂以應報觀點為主要發展方向。關於前者，國內文獻雖早已有對綜合理論之介

48 NORVAL MORRIS, MADNESS AND THE CRIMINAL LAW 182-87 (1982).

49 王皇玉 (註15)，頁615。

50 Frase, *supra* note 2, at 132.

51 高橋直哉 (註30)，頁150-151；王皇玉 (註15)，頁615。國內文獻有稱此分類為「具預防機能的應報刑論」與「應報限度內的目的刑論」(謝煜偉 (註38)，頁155)，惟考量國內多以綜合理論稱之，故本文採前者。

52 城下裕二，量刑基準の研究，頁133 (1995年)。

53 此理論係指在調和應報與預防來建構量刑準則時，將依應報觀點來形塑的量刑責任所對應之刑罰程度理解為一定的幅度，並允許在該幅度內考量犯罪預防之必要性，決定最終之宣告刑。參見：武內謙治、本庄武，刑事政策学，頁188 (2019年)。

紹⁵⁴，不過並未有明確立場選擇。現今主張較明確者如王皇玉是在調和不同刑罰目的並節制國家刑罰權的基礎上，自應報的綜合理論來提出解釋適用刑法第57條的方向，認為應以基於應報而生的罪責原則為基礎，但允許在該原則決定之量刑範圍內，考量威嚇與社會復歸對犯罪預防之效果來調整量刑⁵⁵。此外，謝煜偉針對實務上死刑量刑基準之適用，建議採取的二階段審查基準，同樣較偏向應報的綜合理論的立場：先基於罪責原則審酌刑法第57條所列十款事項，判斷被告之犯罪情節、所犯之不法及責任程度，是否達到從罪刑均衡或一般預防之觀點來看得科處死刑之情形。接著，當犯罪責任程度達到最嚴重而不得不選擇死刑的狀況時，再另外考量對行為人的特別預防效果，透過更生可能性判斷有無迴避死刑的可能⁵⁶。不過，雖然這些論者確立以應報作為量刑基礎，同時主張應自應報思想來形塑量刑責任⁵⁷。但是，對於「應報」此抽象概念，這些論述中並未見到有關概念內涵較明確的分析與討論，也導致量刑責任的概念形塑欠缺較詳盡的論證。由此觀之，對應報內涵的詳細說明及由該內涵建構量刑相當原則之完整推導，可謂是我國量刑理論試圖更精緻地發展時，須面對的問題之一。

惟若將目光轉向以絕對應報論發展論述的文獻時，以許家馨為例，異於過往文獻欠缺對應報意涵的檢討而導致理論蒼白的現象，其嘗試與刑罰情緒論、公平遊戲論及溝通應報論等當代應報理論對話，並據此主張以溝通模式詮釋應報內涵，可謂是國內對應報意涵最全面性檢討與分析的論述⁵⁸。話雖如此，除了其採取之立場是否

54 蘇俊雄（註3），頁406-413。

55 王皇玉（註15），頁616-617。

56 謝煜偉，論「教化可能性」在死刑量刑判斷上的意義與定位：從最高法院102年度台上字第170號判決到105年度台上字第984號判決之演變，臺北大學法學論叢，105期，頁144（2018年）。

57 王皇玉（註15），頁616。

58 許家馨（註23），頁228-257。

適宜，尚有與之商榷的必要外，其對如何由採取之應報意涵來詮釋非難傳遞與嚴厲處遇的關係，以及如何進一步建構量刑相當原則與量刑責任等概念，則未有深論。換言之，即令就應報意涵進行詳盡論述，如何將其延伸至建構量刑相當原則等概念的層次，會是我國量刑理論發展必須面對的問題之二。

不過，目前在同屬絕對應報論的觀點中，事實上已有論述兼及上述二項問題的國內文獻。另外，雖然Tatjana Hörnle並未將華語世界的刑罰理論納入其觀察視野，但若借用其統整當代英語與德語世界應報理論後，所區分出的兩組類型：聚焦在規範秩序之侵害與回復的「規範導向型（Normorientierte）」與關注犯罪人個人於刑罰中之角色，強調個人作為主體對犯罪負責的「個人導向型（Personenorientierte）」⁵⁹，則可發現以下簡介的國內觀點，正可對應於這二組類型而與當代應報理論的發展相契合。如周漾沂偏向於所謂「規範應報論」的觀點，強調現實法秩序的規範妥當性，認為刑罰所追求的並非抽象正義的實現，而是透過維持法秩序與規範妥當性，保障法秩序下各成員的自由與自律性⁶⁰，可歸類為偏向規範導向型。在其理解下，作為可普遍化的行為準則，人們應按照可以自己的自由與他人的自由取得合致的準則而行動。而在此「自由」係指人的現實性外在自由，亦即「權利」的脈絡下，人們在社會中享受不受他人干涉之自由的同時，也會尊重他人的自由而負有不干涉之義務，進而構築相互承認之法權關係。而犯罪即是對普遍化行為準則的否定，也就是對法權關係的破壞⁶¹。如此一來，刑罰並非追求未來確認、強化公眾的規範意識，而是透過對犯罪的再否定來回復過往為其所破壞之法權關係以及人們對法秩序規範效力之信

⁵⁹ Hörnle (Fn. 45), S. 31.

⁶⁰ 周漾沂，論攻擊性緊急避難之定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁422-424（2012年）。

⁶¹ 周漾沂（註6），頁290-293。

賴⁶²。在此脈絡下，由於刑罰是針對主張無法普遍化之錯誤行為準則的犯罪，去揭露其錯誤並使受損的規範效力回復，故自可推導出犯罪與刑罰應對應之「罪刑均衡」的結論。

不同於強調法權關係與規範效力回復的觀點，如許家馨則將刑罰理解為一方面傳達對等犯行嚴重性之非難於犯罪人，另一方面使犯罪人傳達悔悟、自新、和解的訊息，可說是著眼於犯罪人作為道德主體承受刑罰來為其犯行負責的面向⁶³，而偏向個人導向型之觀點。此外，另一個值得注意的是謝煜偉所提出的「修正的社會應報論」。根據該理論，刑罰除應報意義外，也具有消極處理因犯罪所生之損害與修補因加害而破損之社會互動關係的目的。如此一來，即應注意到犯罪除了行為人的選擇外，其實也受社會環境之影響。在此前提下，其透過迴避如許家馨理論所適用的「責任追究對應於犯罪事態」的近代刑法責任觀，從主張社會中責任追索之實像為「社會上透過刑罰的使用以平穩國民法感情及道德秩序，而根據處罰之需要貼付相對應的責任」的觀點切入⁶⁴，推導出應在考量個人責任後也考量社會間接責任之主張⁶⁵。透過以上的爬梳，我們一方面可發現到一條由釐清應報意涵來推導出量刑責任的理論建構路徑，另一方面也可發現應報、量刑責任等概念內涵的多義性，而這些都將成為本文嘗試形塑自身立場時，須進行之推論以及與國內現存觀點對話時的重點。

四、理論建構之核心課題

綜上所述，本文將順著我國學界目前量刑理論發展主軸，也從應報觀點來建構量刑相當原則與量刑責任之內涵。對此，本文將依

62 周漾沂（註6），頁312-316。

63 許家馨（註23），頁255-257。

64 謝煜偉（註38），頁185。

65 謝煜偉（註38），頁192-194。

序回應「應報內涵與建構的量刑相當原則內涵為何」與「由量刑相當原則推導的量刑責任概念為何」等課題，來建構各概念內涵。同時，在回應第一個課題的過程中與國內現存觀點進行對話，嘗試說明作為本文理論基礎的應報內涵為何。以下，先簡要說明理論建構時，須回應的二個課題內容。

（一）確認應報意涵與建構量刑相當原則

首先，本文要透過對當代應報理論之分析與檢討，尋找適當的應報意涵來建構量刑相當原則⁶⁶。詳言之，在刑罰係由非難傳遞與嚴厲處遇所組成的前提下，個案量刑即是透過量定刑罰輕重來決定施加於犯罪人之不利益，而量刑相當就是在探討如何在非難傳遞與嚴厲處遇的相互關係中，於傳遞非難於犯罪人的同時，合比例地施加不利益於犯罪人。至於「應報」，其並非要透過刑罰來追求未來犯罪預防之效益，而是基於本務論（deontological）的觀點，認為犯罪行為是具有可非難性的，故透過刑罰對犯行傳遞負面評價與施加不利益本身即是實現基本正義或符合道德義務⁶⁷。如此一來，當以應報為目的來建構量刑相當原則時，最首要的工作即是釐清應報的意涵，特別是選擇理論核心所追求之正義或道德原則，能夠符合本文所理解之「適度刑罰」的應報意涵。接著，再透過該意涵來詮釋非難傳遞與嚴厲處遇間的關係及該關係下嚴厲處遇所代表的意

66 在此須說明本文是偏向刑罰哲學的路徑，故在「理論建構→具體實踐」的順序上，不同於比較法研究著重在後者，選取特定區域之量刑制度與我國比較或建議適用，本文是在前者中與當代理論進行對話，於嘗試形塑應報正義的抽象內涵時，提供我國更多想像的可能。換言之，不同於比較法研究須強調引介或比較制度與本土的關聯，哲學思考側重價值辯證與概念內在的邏輯推演，故無論是英語或德語世界的刑罰哲學討論，當二者互相對話的皆是應報、嚇阻、教化等相同核心概念時（樋口亮介，行為責任論を基礎にした前科の位置づけ——近時の英米法圏の学説を素材に，收於：高橋則夫等編，刑事法學の未來——長井圓先生古稀記念，頁181（2017年）），自可將各理論關於價值選擇與邏輯推演之討論皆納入對話範圍中。不過，若要將對話後形塑出的應報概念具體實踐於我國法時，在實踐層次仍必須注意本土脈絡有無容納該抽象概念的可能。

67 許家馨（註23），頁210。

義。藉此，才可釐清該應報意涵下之合比例刑罰量定所指為何，完成量刑相當原則之建構。

而在釐清應報意涵時，應注意到雖然傳統多將應報化約為「以牙還牙、以眼還眼」⁶⁸，亦即Immanuel Kant主張刑罰必須相當於犯罪的同害報復觀（*lex talionis*）⁶⁹。但事實上在1970年代應報理論重新復興之後，無論英語或德語世界，當代應報理論可謂百家爭鳴，各自賦予應報多樣化的意涵⁷⁰。同樣地，根據上段對我國理論現況之爬梳，也可發現國內學說關於應報意涵存在數種不同理解。如此一來，當不同應報理論係以相異的正義觀作為刑罰正當性之基礎，故其對非難傳遞與嚴厲處遇之關係及嚴厲處遇意涵之理解也有所差異時，自然不同應報意涵可能會推導出內涵相異的量刑相當原則。換言之，縱使當代應報理論可謂以採用「罪刑均衡」為共同特質，但對應於不同應報意涵與對刑罰量定之詮釋，「罪刑均衡」的實質意義也會有所歧異。在此理解下，理論建構的首要課題自然是檢視各種應報理論的意涵，及各理論對嚴厲處遇內涵、嚴厲處遇與非難傳遞相互關係之理解，尋找最符合本文理解下之適度刑罰的應報觀點，來形塑合比例刑罰量定之樣貌與推導量刑相當原則之內涵。

（二）由量刑相當原則推導量刑責任之內涵

接著，以推導出的量刑相當原則內涵為基礎，說明應如何形塑

68 黃榮堅（註17），頁14。

69 Immanuel Kant, *THE METAPHYSICS OF MORALS: THE CAMBRIDGE EDITION OF THE WORKS OF IMMANUEL KANT: PRACTICAL PHILOSOPHY* 473 (Mary J. Gregor ed. & trans., Cambridge Univ. Press 1996) (1797).

70 英語世界如John Cottingham與Nigel Walker各歸納出9種與11種之理論分類，see John Cottingham, *Varieties of Retribution*, 29 *PHIL. Q.* 238, 238-46 (1979); Nigel Walker, *Even More Varieties of Retribution*, 74 *PHIL.* 595, 595-605 (1999). 德語世界也可見以規範應報論為代表，被稱為絕對應報論復興之現象：Vgl. Bernd Schünemann, *Aporien der Straftheorie in Philosophie und Literatur*, in: Prittwitz (Hrsg.), *Festschrift für Klaus Lüderssen*, 2002, S. 327.

作為量刑基礎的量刑責任的概念內涵。對此，在應報理論採取「罪刑均衡」為共同特徵的狀況下，以行為責任作為量刑責任的內涵，可說是合理的推測。話雖如此，一方面應報意涵的差異即可能影響「罪刑均衡」之實質內容，進而形塑出內涵相異的行為責任概念。另一方面，由於理論上可能對行為責任的內涵存在多樣化的認知，也導致對量刑責任出現不同的理解。以日本學說為例，雖然多數論者是從犯罪行為不法且有責之範圍，來形式上認定行為責任，將責任認定要素限定於與犯罪行為之不法性、有責性相關者⁷¹。但是，如岡藤重光主張之「人格責任論」，即認為行為責任固然重要，但在犯罪行為是犯罪人人格主體之具象化的前提下，不應將犯罪行為及行為背後潛在的人格等分開評價。換言之，判斷決定刑罰程度的犯行可非難性時，判斷內容包括了形式上犯罪行為與犯罪行為背後人格之形成的可非難性⁷²。此外，如平野龍一主張之「性格責任論」中，雖然反對將人格形成之過程作為非難對象，但也認為犯行可非難性的判斷不應僅侷限在犯罪行為形式上的嚴重程度。相反地，鑑於犯罪行為背後存在犯罪人人格、環境或經歷等因素，也應將從該犯罪行為中可顯現限度內的人格因素等，納入犯行可非難性的考量範圍^{73、74}。

71 小池信太郎，量刑における消極的責任主義の再構成，慶應法学，1号，頁284（2004年）。

72 岡藤重光，刑法綱要總論，3版，頁258-262（1990年）。

73 平野龍一，人格責任と行為責任，收於：刑法の基礎，頁38（1966年）。

74 此處論及的日本理論是在討論累犯或前科等犯罪經歷對量刑之影響的脈絡下，希望以責任加重作為累犯或前科加重刑罰依據的產物。這些見解嘗試透過將人格因素與人格形成過程等納入傳統以行為為基礎的責任概念中，進而形塑出人格責任、性格責任等概念，並使用這些概念來證成累犯之加重責任與證立刑罰加重結果。不過，此二理論並非只適用於累犯或前科加重量刑的討論中。事實上，行為人縱然未曾犯罪，其在犯罪前的人生歷程中曾發生可能形塑其人格、性格之事由（如：教育、家庭狀況），仍可能納入量刑判斷中。不過，當將此二理論認知為不限於累犯與前科之討論，而是普遍適用於整個量刑系統時，必須注意其可能發生的問題。由於這些理論承認人格因素與人格形成過程之相關因素可納入量刑考量中，故可能導致責任內涵不再是對過往犯罪的可非難性，而在實質上成為對行為人人格上危險性的非難，改變責任概念的內涵（淺田和茂，

換言之，雖然應報觀點下，普遍承認刑罰輕重之量定必須對應於犯行可非難性。但是，究竟犯行可非難性的內涵與判斷要素為何，實則存在不同看法，這也成為處理量刑責任概念時，必須面對的問題。如有論者觀察我國實務對強制性交或毒品犯罪之量刑，指出存在以成長歷程或生活狀況等因素判斷人格偏差，並以人格責任論的觀點來加重量刑之狀況⁷⁵，呈現出上述日本學說爭議非無在我國量刑理論發展中出現之可能，也顯示有在理論上確認量刑責任內涵的必要。因此，本文確認採用的應報意涵與建構量刑相當原則後，最終即需釐清量刑責任之內涵。

參、當代應報理論之對話與檢討

本文已確立以應報觀點來建構量刑相當原則，亦即立於回顧導向（retrospective）的觀點，僅以過去發生的犯罪或與其相關之事態作為應報對象，且在量刑相當原則的建構上限定於本務論式的理論建構取徑。而在理論建構過程中，必須首要處理的核心問題就是以何種應報意涵作為建構的基礎。對此，本段將先指出本文對應報觀點的選擇基準，接著依循此基準對當代應報理論進行分析、檢討，最終確立本文的觀點。

刑法總論，補正版，頁275（2007年）。此種改變可能造成責任判斷與犯罪行為脫鉤，導致各種事由都可透過人格、性格為媒介來影響量刑，削弱責任原本限定刑罰之功能。除可能導致量刑不安定外，也可能導致刑罰程度遠超過行為責任之範疇，進而產生過苛刑罰的危險。如此一來，若肯認這些理論將犯行之外可能影響可非難性之事由納入責任概念之觀點時，如何能將這些事由納入量刑考量又同時避免量刑不安定或招致過苛量刑之問題，會是須面對的問題。

⁷⁵ 李茂生，台灣刑事政策の近年の動向——二極化の狭間で，一橋法学，13卷1号，頁103（2014年）。

一、應報理論之選擇基準與對話方式

（一）形式上得推導出罪刑均衡之結論

當本文以當代應報理論作為選擇範圍，要選擇一個「比較適合的」應報理論來建構量刑相當原則時，本段要先設定選擇基準。申言之，當不同量刑目的透過對嚴厲處遇與非難傳遞之內涵及相互關係的詮釋，形塑出各種合比例刑罰量定之意涵時，量刑目的選擇之關鍵，就在於究竟什麼樣的合比例意涵可符合我們對「適度的刑罰」的理解。至於適度的刑罰所指為何，實則取決於我們對刑罰之理解，以及對作為刑罰實踐的量刑判斷背後所要追求之價值與目標的選擇。故當我們選擇應報作為建構量刑相當原則之量刑目的時，自然象徵我們將應報觀點普遍要求的罪刑均衡之量刑，理解為適度的量刑。而在此選擇背後，必然是我們認為相對於其他目的，以應報為目的之量刑能夠避免某些問題或具備某些優點。如此一來，我們勢必要從當代應報理論復興的背景談起，瞭解當代應報理論是為了處理何種問題而興起，以及其所宣稱之優點何在，藉此形塑出挑選比較適合的應報理論時，所適用的選擇基準。

由於當代應報理論復興被普遍認知為起源自對目的刑理論的回應⁷⁶，故雖然本文並未要詳細討論目的刑理論之良窳，但為說明此現象進而帶出當代應報理論主張自身所具之特點所在，以下即在釐清當代應報理論復興的範疇內，簡述目的刑理論在理論與事實層面遭遇的困境。首先，由於目的刑理論係以未來犯罪預防及再犯防止之效果作為量刑判斷之標準，導致依此理論進行量刑時之考量重點並非犯行本身可非難性，而是行為人再犯危險性或公眾得被嚇阻或強化規範意識之效益。如此一來，除了現實上再犯危險性與犯罪預

76 德語世界此狀況之介紹參見：飯島暢（註43），頁332。英語世界此現象之描述，see DAVID GARLAND, THE CULTURE OF CONTROL: CRIME AND SOCIAL ORDER IN CONTEMPORARY SOCIETY 55-59 (2001).

防效果能否被有效實證的問題外⁷⁷，在理論面上將此種不明確且具預測性的要素納入量刑相當原則與量刑責任之概念時，加上公眾意識等因素存在受犯罪所喚起之強烈懲罰慾望之情緒反應影響的風險⁷⁸，可能導致責任範圍浮動而無法明確限定刑罰之情況，進而有招致不合比例刑罰的可能^{79、80}。

誠然，針對上述第一項質疑，目的刑理論會主張其並非為追求犯罪預防而容許無限制地訴諸嚴刑峻法⁸¹，而是會將刑罰的邊際遞減效應納入考量，也一併考量犯罪查獲率、起訴率、定罪率等來決定刑罰輕重，故未必導致不合比例之嚴罰結果⁸²。不過，此種回應並無法迴避另一項對於目的刑理論之批評，亦即此理論以懲罰犯罪人作為追求犯罪預防效益之手段，有將犯罪人客體化、工具化之傾向。具體言之，如在一般預防理論的脈絡下，當量刑取決於能否回復與確證公眾規範意識或能否嚇阻潛在犯罪人進而預防犯罪時，犯罪人淪為追求此效益之工具或不具理解能力且無對話必要的客體⁸³，

77 ANDREW VON HIRSCH, DESERVED CRIMINAL SENTENCES 9 (2017).

78 吉岡一男，犯罪の研究と刑罰制度，收於：刑事制度の基本理念を求めて——拙稿とその批判の検討，頁110（1984年）。

79 本庄武，刑罰論から見た量刑基準（2），一橋法学，1卷2号，頁425、447、469（2002年）。

80 對此質疑，有持特別預防理論者嘗試將犯行可非難性納入量刑考量，主張刑罰輕重應對應於犯罪人的可非難性，若可非難性越高，透過刑罰再社會化的必要性也越高，與之相對應的刑罰程度也越重（高山佳奈子，故意と違法性の意識，頁108-109（1999年）；E. THOMAS SULLIVAN & RICHARD S. FRASE, PROPORTIONALITY PRINCIPLES IN AMERICAN LAW: CONTROLLING EXCESSIVE GOVERNMENT ACTIONS 163 (2008)）。誠然，此主張修正了再犯可能性作為預測性要素而難以實證的問題，避免因責任概念浮動而導致刑罰不合比例之風險。惟若考慮到與再犯具關聯性之因素眾多，犯行可非難性可能僅是推論基礎之一而未必與再犯間具有因果關係，此理論之推論可能有過於簡化再犯可能性判斷之嫌，能否確實修正目的刑理論之問題，實值商榷。

81 See David D. Friedman & William Sjostrom, *Hanged for a sheep: The Economics of Marginal Deterrence*, 22 J. LEGAL STUD. 345 (1993).

82 相似意見：黃榮堅（註17），頁17。

83 城下裕二，量刑事情の意義と限界，收於：量刑理論の現代的課題，增補版，頁71（2009年）。

並未被看作主體來對待⁸⁴。或者，在消極特別預防理論的脈絡下，由於刑罰輕重取決於能使犯罪人感受到高於犯罪利益的侵害進而達成嚇阻再犯之效果，故同樣面對將犯罪人看待為動物般之批評⁸⁵。甚至是在基於人道主義思維而以教化來防止犯罪人再犯的特別預防理論中，也遭遇基於矯治主義思想將犯罪行為假設為個人病徵時，有如在欠缺犯罪人之病患同意下透過懲罰來強加治療，為公眾利益而忽略個人利益之質疑⁸⁶。現實上，若從當代刑事司法發展來看，在以風險控制與消除犯罪恐懼為主軸導致嚴罰化趨勢的現況下，實行流放形式的嚴厲性隔離策略（*punitive segregation*）等將犯罪人標示為危險源進行排除的刑罰實踐本身，即可謂呈現出刑罰權力將犯罪人對待為具危險性之客體，為追求防止犯罪之效益而加以排除的發展方向⁸⁷，某程度呼應上述理論面之質疑。

事實上，當代應報理論復興正是對應上述質疑而生，一方面重新確立刑罰與犯罪間的連結，另一方面則強調應在刑罰施加的階段中將犯罪人對待為主體，進而產生以強調罪刑均衡作為核心之理論特質。而當代應報理論以罪刑均衡為核心時，其理論基礎除了強調刑罰的公平性外，同時也強調行為人作為理性自律之主體，應透過刑罰來對自身所為犯行負責⁸⁸。詳言之，當代刑法的架構下預設了人作為對規範具有理解能力且能依據規範來引導其行為，可基於其自律、自主（*autonomous*）決定做出行為選擇並為該行為負責之理性自律主體形象，人們選擇共同構成法的社群並基於對彼此遵守法律之信賴而經營社群之共同生活，並具有在基於自由意志選擇違犯

84 VON HIRSCH & ASHWORTH, *supra* note 34, at 15.

85 *Id.* at 137.

86 GARLAND, *supra* note 76, at 56; 飯島暢（註43），頁334。

87 李茂生，風險社會與規範論的世界，月旦法學雜誌，173期，頁148（2009年）；GARLAND, *supra* note 76, at 140, 178, 194.

88 VON HIRSCH, *supra* note 77, at 12; 飯島暢（註43），頁335。

刑法法規時承擔相應責任之資格⁸⁹。此種理性、自律、自主的市民、理性人形象正是近代刑法之所以成為可能的基本前提，其作為刑法罪責原則之基礎⁹⁰，也同時成為支撐當代應報理論的核心價值。亦即，當代應報理論立基於對目的刑理論客體化犯罪人之批評，而回歸理性自律主體之設定，主張具正當性之刑罰必然是以行為人基於理性、自律之主體身分來接受刑罰之宣告及執行，進而對其犯罪行為負責之思考為基礎，不得將犯罪人視為僅是單純承受刑罰所施加痛苦之客體⁹¹。也正是此種刑罰作為犯罪人為犯行負責之設定下，當代應報理論重新強調刑罰量定與犯罪間的連結，從刑罰必為對犯罪之回應中，形成罪刑均衡之核心特質。同時，由於「罪刑均衡」強調刑罰程度必須對應於犯行嚴重性，故刑罰程度必然也被限定在該對應範圍內。如此一來，在以風險控制與犯罪預防為主軸的當代刑事司法中，即可限定刑罰並使之免於過度甚至是無限度嚴罰化的問題⁹²。

89 VICTOR TADROS, CRIMINAL RESPONSIBILITY 44, 76 (2005); 謝煜偉 (註38)，頁158。

90 王皇玉 (註15)，頁319。

91 Jean Hampton, *An Expressive Theory of Retribution*, in RETRIBUTIVISM AND ITS CRITICS 1, 14 (Wesley Cragg ed., 1992).

92 對此的可能質疑是應報理論其實較目的刑理論更為嚴厲。對此，筆者認為應釐清談論的層次究竟是理論面或實然面。誠然，由於應報理論復興與英美刑事政策嚴厲化的走向在歷史發展的時間點上相吻合，導致其常被誤解為促成嚴厲刑罰的原因（歷史發展，see JAMES Q. WHITMAN, HARSH JUSTICE: CRIMINAL PUNISHMENT AND THE WIDENING DIVIDE BETWEEN AMERICA AND EUROPE 56-62 (2005); GARLAND, *supra* note 76, at 3-4）。但此實然面的結果其實來自政治、經濟與社會因素所促成，並未能全然歸因於應報理論之發展，且純以實然的操作結果來質疑哲學層次之理論推導並不合理。此外，在實際操作中，以我國死刑量刑為例，將更生教化納入死刑量刑考量時，雖然有在基於應報觀點考量犯行嚴重性外，思考未來教化可能而迴避死刑的餘地。但是，也可能存在翻轉觀察教化可能性的視角，將犯罪人欠缺教化可能作為死刑要件，結果因教化可能性欠缺明確預測基準，反而導致難以迴避死刑結果的可能（謝煜偉，「永山基準」台灣版？——死刑量刑基準的具體化，台灣法學雜誌，249期，頁217（2014年））。因此，本文認為比起基於犯罪預防效果之預測，基於罪刑均衡之量刑在理論上確實較能限定刑罰程度。而在實然面上，確實可能在不同個案中操作出應報或預防觀點之量刑較嚴厲之情形，但單純抽出個案中出現預防觀點量刑較輕之案例，並不足以作為否定本文理論層次推導之依據。

綜上所述，本文認為在確立作為理論建構基礎之應報觀點時，第一個選擇基準是形式上從該理論能夠推導出刑罰量定應與犯行嚴重性合比例，亦即罪刑均衡之結論。詳言之，由於當代應報理論對應報意涵之解釋相當多樣化，雖然都以作為理性自律主體之犯罪人應承受刑罰施加之不利來為自身犯行負責，作為其理論核心，但實質上論理各異：有認為行為人必須負責是因為罪有應得者、有認為是因為犯罪人不法獲得額外利益者，也有認為犯罪人是為了表現其贖罪者。在此狀況下，本文第一個要檢視的就是各種應報理論在推論上是否確實可推導出罪刑均衡之結論，以能否推導出該結果作為形式上的選擇基準。

（二）實質上維持犯罪人之主體性

不過，只是形式上符合罪刑均衡就一定是適合的應報理論嗎？或者，能夠推導出罪刑均衡的結果，就確實可在刑罰量定時維持犯罪人主體性嗎？對此，本文認為僅是形式上可推導出罪刑均衡之結論是不夠的，由於對應報意涵的不同理解會導致「罪刑均衡」之實質內容產生差異，故除了前段的形式上基準外，還應該檢視各理論所推導出的罪刑均衡內容，判斷其實質上能否確實維持犯罪人之主體性。事實上，根據此實質的選擇基準，本文可初步劃定本文對話對象的範圍。

詳言之，以被本文歸類為規範導向型的見解來說，雖然該見解認為刑罰程度應對應犯罪對法權關係與規範秩序造成的侵害，故可導出罪刑均衡之結論，但實質上是否可維持犯罪人主體性，則有商榷的餘地。申言之，由於其是從設定一個在共存事項上可普遍化的行為原則為出發點，來建構法權關係與規範秩序，故其主張之規範秩序實則是與各市民個人利益相分離而擬制出的客觀、現存的法秩序⁹³。

⁹³ Hörnle (Fn. 45), S. 33.

若是如此，則市民間對彼此自由之相互承認關係，即可能是由多數主流價值所擬制出的社會共同心理狀態⁹⁴。姑不論其實質內涵有無可能被檢證，理論上即可能存在部分市民因文化或價值差異而非自律地接受該規範效力，卻被擬制為承認此相互關係與規範秩序。如此一來，即可能發生因文化衝突或社會結構壓迫，導致侵害該規範秩序之犯罪成因被忽略而未能納入量刑考量，忽視個案中犯罪人主觀上價值可能存在與客觀法秩序間之衝突乃至於受其壓迫的狀況。換言之，縱使此觀點下之刑罰形式上符合罪刑均衡，但在未正視個體價值差異時，恐難被評價為可在個案量刑中維持犯罪人之主體性。

如此一來，本文主要將以個人導向型的應報理論為對話對象。不過，這並不代表屬於此類型的理論在可推導出罪刑均衡的前提下，實質上就必然可在量刑時維持犯罪人之主體性而屬於本文對話範疇。以謝煜偉的觀察為例，其即指出在近代刑法與刑罰權正當性係以社會契約論為基礎，而以市民締結社會契約為預設的前提下，此前提本身即蘊含市民與非市民（社群之敵人）的二元概念區分。而當近代刑法乃至於當代應報理論係以理性自律主體作為預設時，就可能在強調理性主體形象時，無可避免地形塑出屬於例外非市民形象之他者⁹⁵，亦即出現將犯罪人客體化的情況。

對此觀察，雖然本文並非自社會契約論切入，但持贊同立場。詳言之，法官量刑決定對犯罪人生命、自由或財產等權利施加不利益之程度時，可說是啟動將犯罪人自其社會中應有位置排除、使之降格（*degradation*）的機制⁹⁶。當然，國家刑罰權力的行使，最終未必將犯罪人徹底排除於市民社會外或降格到淪為客體的程度，但無可否認此權力機制的啟動，即代表犯罪人在一定條件下無法抵抗

94 謝煜偉（註38），頁161。

95 謝煜偉（註38），頁171-173；李茂生（註75）頁103-106。

96 WHITMAN, *supra* note 92, at 20.

將其客體化的權力運作⁹⁷。亦即，當法官量刑作為最終刑之執行的基礎時，該量刑可能成為回應社會對犯罪恐懼與追求社會成員安全感之工具，以犯罪所呈現之行為人人格、危險性作為評價對象，而使犯罪人承受使之淪為客體的刑罰量定，但也可能透過對犯罪成因與結果之充分評價，將刑罰程度盡可能限定在對應該評價之範圍內，呈現行為人為行為負責之意涵，盡可能彰顯其主體性⁹⁸。換言之，法官量刑是在當國家刑罰權力機制啟動後，面對立法者制定之法定刑規範與社會輿論，可決斷最終刑罰會偏向維持行為人主體性或將之視為危險源而作為客體排除的控制階段，而二種發展方向皆有可能，至於實際發展則取決於法官對刑罰的認知、對量刑目的之選擇與評價犯罪的面向。在此理解下，雖然本文選擇以宣稱維持行為人主體性之應報觀點作為量刑目的來展開論述，但該觀點是否能確實維持行為人主體性則非必然。舉例來說，堅守以理性平均人能力作為評價犯罪與判斷行為人負責範圍之基準時，理論上即有忽視個別犯罪人在主流價值下存在特殊性之可能。或者，將目光單純聚焦於行為人犯行時，也可能忽略個人與社群之連結，進而忽視犯行、個人與社群間複雜的互動關係。而在這些以主流文化與優勢族群作為理性主體形象或忽視個人作為社群成員之面向的狀況下，是否量刑確實可謂是使犯罪人對自己犯行負責並充分維持其主體性，應有深入檢討的必要。

因此，本文認為從實質上維持犯罪人主體性的角度觀之，法官量刑固然應聚焦於個案中特定犯罪人及其犯行，但不應忽視個人與社群之互動關係。亦即，當刑罰是針對犯罪人與一般市民間行為選擇上之差異而給予限制權利之差別對待時，應將不同個體的差異性

97 顏厥安，不再修補殺人機器——評論許家馨與謝煜偉教授有關死刑之文章，中研院法學期刊，17期，頁365（2015年）。

98 Kurt Seelmann, *Does Punishment Honour the Offender?*, in *LIBERAL CRIMINAL THEORY: ESSAYS FOR ANDREAS VON HIRSCH* 111, 112-14 (AP Simester, Antje du Bois-Pedain & Ulfrid Neumann eds., 2014).

與在社群中的位置差異納入考量，嘗試緩和、降低犯罪人因個人與社群主流價值之差異而在量刑時被過度差別對待之可能。或者，若當代應報理論宣稱罪刑均衡可達成「公平(fair)」的理想時，應盡可能從價值多元主義的角度去注意行為背後可能存在的個體差異與價值衝突，在量刑時追求實質的公平，而非形式上的罪刑均衡而已。唯有如此，才可能在刑罰具有剝奪他人權利與更深層地排除他者的性質下，於必須接受刑罰存在於社會中的現實時，將其量定限定在維持犯罪人主體性之範圍內，並進而影響後續之執行。

(三) 本文之對話方式

根據以上設定之基準，本文以下將進行理論對話，透過分析與檢討不同應報理論來形塑自身觀點。不過，對話的方式則會與目前同樣著眼於犯罪人主體性的國內見解略有差異。以前面提及的「修正的社會應報論」為例，在當代應報理論以理性自律主體之預設為前提，但仍可能例外化他者為非市民的狀況下，其一方面並未完全放棄該預設，一方面則嘗試架構出能兼顧個人及其所處社會環境之量刑理論⁹⁹。不過，此理論雖然成功處理了應報理論背後面對的深層困境，從刑罰作為修復個人與社會互動關係的角度來證立將社會責任納入量刑考量的論點。但是，由於其採取筆者稱為迂迴戰術的路線，亦即在理論建構中某程度迴避了當代以個人對犯行之責任為中心塑造的責任觀，因而產生在其所採責任觀下，應如何將社會責任於理論操作上反饋於個人責任之疑問¹⁰⁰。

基於上述觀察，本文嘗試採取另一條筆者稱為滲透戰術的路線，亦即透過與當代應報理論對話，嘗試對當代應報觀點進行修正或重構，並在個人責任的責任觀中形塑能夠兼顧行為人與社群之關係及其個人價值的論述。亦即，本文希望能形塑一種以尊重多元價

99 謝煜偉(註38)，頁177。

100 顏厥安(註97)，頁351-352。

值為本，使犯罪人僅在個人價值被尊重且在社群中擁有充分行為選擇可能之範圍內作為主體來對其行為負責的應報觀點，並根據該觀點來說明刑罰中非難傳遞與嚴厲處遇間的關係，以及該關係下嚴厲處遇的意涵¹⁰¹，進而建構量刑相當原則與量刑責任之內涵。更深入地說，本文要在推導罪刑均衡之結果並兼顧犯罪人主體性之維持的前提下，說明應如何理解「刑罰程度應對應於犯行可非難性」之內涵，並清楚指出應納入「犯行」考量範圍之要素。不過，考量到應報理論類型眾多，勢必難以一一檢視，故參考Jesper Ryberg依理論內涵為基準的分類手法，並選擇與國內量刑學說討論相關者，將應報理論區分為「單純應得」、「公平分配」與「表現與溝通」等模式¹⁰²，並依前述選擇基準來分析與檢討各類型，作為形塑本文立場之基礎。

二、單純應得模式

「應得」作為應報主義最鮮明的特色，判斷對某犯罪施加之刑罰是否「應得」，始終是應報理論的核心：其訴諸犯罪應得到懲罰，而非可得的未來效益，來證立刑罰¹⁰³。由於本文另外要對話的二種模式，實際上是透過深入詮釋「應得」之意涵來進行理論建構，因此本段將先著眼於這些理論的基礎類型，亦即單純以犯罪人應得懲罰為宗旨的單純應得模式（simple desert），透過分析此類型來便於說明後續二模式為何要對「應得」進行更詳細之解釋來充實其內涵。

根據顏厥安之定義，「應得」是基於道德、貢獻、責任等評價觀點，我們認為某個人有資格值得獲得某種正面的利益，或應受到

101 VON HIRSCH, *supra* note 77, at 19; DUFF, *supra* note 23, at 82.

102 JESPER RYBERG, THE ETHICS OF PROPORTIONATE PUNISHMENT: A CRITICAL INVESTIGATION 12 (2004).

103 David Dolinko, *Some Thoughts about Retributivism*, 101 ETHICS 537, 541-42 (1991).
國內文獻見顏厥安（註97），頁340；許家馨，（註23），頁210。

某種譴責、懲罰等負面的對待。為了運作「應得」與否，通常需建立功績體系（merit system）¹⁰⁴。簡言之，宣稱「應得」必然是以某人具有某項特點或做了某行為基礎，進而決定什麼是該人應得的內容，沒有依據地主張「應得」某內容，將本質上牴觸宣稱「應得」的邏輯。而應得的基礎有被認為建立在承認每個人掌握自身命運的權力上，亦即在依賴相互合作的社會中，承認「應得」可使人們知曉他人對待己身的好壞¹⁰⁵。在此之中，各式各樣的「應得」的判斷常是價值判斷，而未必是道德判斷¹⁰⁶。不過，在單純應得模式的理解中，法官針對犯罪與刑罰間的「應得」判斷，則被認為是建立在作為該模式核心內涵且具有道德重要性的宣稱上：犯錯之人應經受不利益¹⁰⁷。換言之，此宣稱本身含有基本的道德價值，如John Kleinig即主張此宣稱的基礎在於對正義最深切的直覺¹⁰⁸。在此理解下，決定犯罪人應承擔刑罰的量刑判斷，可以說是為判斷其因犯罪而應經受的不利益程度，運作刑罰是否應得而設的功績體系，至於量刑相當原則則可理解為連結此模式核心內涵與量刑功績體系運作間的重要樞紐。此時，從「犯錯者應經受不利益」之核心內涵得否推導出罪刑均衡之結論，就成為首先要檢視的重點。至於檢視對象，則是此推導所包括的三個命題：（一）犯罪人應得與其犯行嚴重性合比例的不利益；（二）當刑罰愈加嚴厲，被懲罰者即遭受更多不利益；（三）故犯罪人被懲罰時，刑罰嚴厲性應與犯行嚴重性合比例¹⁰⁹。

104 顏厥安，何謂正義？一個初步的理論說明，收於：社團法人台灣法學會編，*台灣法學新課題*（十），頁14（2014年）。

105 James Rachels, *Punishment and Desert*, in *ETHICS IN PRACTICE* 470, 474 (Hugh LaFollette ed., 1997).

106 顏厥安（註97），頁353。

107 Lawrence H. Davis, *They Deserve to Suffer*, 32 *ANALYSIS* 136, 139-40 (1972).

108 其例為躲到無人島種田的納粹戰犯，即使在30年後被發現時沒有離開該島或繼續為惡的意思，仍應受罰。See JOHN KLEINIG, *PUNISHMENT AND DESERT* 67 (1973).

109 RYBERG, *supra* note 102, at 16.

由於對犯罪人施加越多不利益，應可合理地理解為刑罰更嚴厲，故命題（二）較無爭論的狀況下，本文把檢討重心先放在命題（一）之上。首先，命題（一）存在一個推論上的問題，亦即「犯罪人應經受不利益」如何直接推導出「犯罪人應經受與犯罪行為嚴重性合比例之不利益」，二者存在邏輯上的跳躍。事實上，此問題正起源於此模式將犯罪人應經受不利益的基礎放在道德上的直覺，而未對犯罪人為何應經受不利益更具體的說明。亦即，由於本理論未處理刑罰本質中施加不利益之嚴厲處遇的定位為何，進而導致該不利益所指涉的範圍不明。這導致不利益的範圍可謂毫無界限，包括犯罪人生病、喪偶喪子皆可能涵括在內，而未限定於與犯罪具有關聯性。故如何推導出命題（一）的結論，即有疑義。而當命題（一）無法說明為何不利益範圍可限定於犯罪行為相關者時，如何能再推論到命題（三）中量定刑罰之不利益程度應與犯罪相當，勢必有再補充論證的必要。

總結以上，可以說此模式面臨的挑戰，在於犯罪人應經受的不利益本質上未限定在與犯罪相關者。這除了動搖命題（一）的存立外，當量刑時將犯罪人其他經受不利益納入考量而調整刑度時，縱然承認命題（一）所說的「犯罪人A應經受與 t_1 時點所為犯罪C合比例的不利益S」，也未必能推導出法官有「應施加與 t_1 時點所為犯罪C合比例的不利益S於犯罪人A」之義務的結論¹¹⁰。若檢視具此模式特點的理論，可更清楚發現以此模式建構量刑理論時，足以動搖其推論妥當性的問題。以Gertrude Ezorsky所提出的「整體人生觀點（the whole life view）」為例，其主張不僅是犯罪時與犯罪後之事態，發生於犯罪前的事態也應納入犯罪人最終「應得」的計算中¹¹¹。此外，與我國所採應報的綜合理論內涵相似的日本學說中，

110 *Id.*

111 Gertrude Ezorsky, *The Ethics of Punishment, in* PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES ON PUNISHMENT, at xi, xiv (1972).

如原田國男與井田良皆主張可將與行為責任或犯罪預防之考量無關的要素，作為「中立的犯罪輕重調整原理」之量刑事由而納入量刑考量中，如犯罪人在偵查過程受到違法偵查所施加的痛苦¹¹²、因犯罪導致親人身亡而生的悲痛等，都可看成預先承受應得的痛苦與不利益，進而降低應報與刑罰之必要性¹¹³，故應將這些不利益的量由同屬對犯罪人不利益之刑罰中扣除，來精確求得「應得」的程度。

不過，上述理論透過將刑罰與其他被告遭遇的痛苦都等同視為其曾經受之不利益而全部納入「應得」的計算中，雖看似堅守單純應得的思考邏輯且提出將犯罪人經受的非懲罰性不利益納入量刑考量的論據，但也導致下述問題的產生：第一，事實上，即使是認為判斷應得之刑罰時可能將先於犯罪之事項納入考量的主張中，亦非不設限地承認所有犯罪人經受之不利益皆可影響量刑¹¹⁴。如Ezorsky就針對「先因冤獄被監禁一年者，是否因而取得犯罪的權利？是否未來犯罪時可主張從刑期中扣除一年？」之疑問，提出否定的回應¹¹⁵。但是，為何此不利益不得影響犯罪人應得之刑罰？不利益得否影響量刑的類型區分與判斷基準為何？相關說明可謂付之闕如。對此，同採應報的綜合理論的日本學說中，有主張犯罪人因犯罪而使自己承受不利益時，應以該不利益源自「自作自受」的程度高低，作為該不利益可否納入量刑考量的判準¹¹⁶。但在自作自受可謂亦屬仰賴直覺之道德判斷的前提下，縱然不利益是犯罪人自身所招致，其終究是先經受了不利益，故為何此時不得影響犯罪所應

112 原田國男，*量刑判断の実際*，3版，頁166-167（2008年）。

113 井田良，*量刑理論と量刑事情*，現代刑事法，21号，頁41（2001年）（以下簡稱：井田良，*量刑理論と量刑事情*）；井田良，*量刑理論の体系化のための覚書*，*法學研究*，69卷2号，頁305（1996年）。

114 RYBERG, *supra* note 102, at 18.

115 Ezorsky, *supra* note 111, at xxv.

116 畑山靖，*被告人が自己の犯罪により自ら多大の不利益を被ったことと量刑*，收於：大阪刑事実務研究会編，*量刑実務大系*（第3卷）：一般情状等に関する諸問題，頁229（2011年）。

得的刑罰不利益程度，即有論證之必要。第二，縱然肯認前述論點，此理論之根本難題在於不利益性質相異時如何相互扣減。亦即，不利益間可相互扣減，應以二者性質上相同為前提。惟若思考刑罰本質除施加不利益外，尚包括傳遞非難時，則不具懲罰性質的不利益為何可由應得的刑罰程度中扣除，應有檢討的餘地。本文認為，若肯定不具懲罰性質的不利益可影響應得的刑罰程度時，現實上無異於承認與犯行嚴重性無關的不利益，可納入合比例刑罰量定的考量中，可謂自始無法推導出命題（三）中罪刑均衡之主張。

綜上所述，針對命題（一）的內容，若要能推導出罪刑均衡之結論時，則應設法建構僅與犯罪相關之不利益才可納入量刑考量之主張。但如此一來，等同有必要建構新理論來說明可影響犯罪人應得之刑罰的不利益，為何須限定在具懲罰性質或與犯行相關者。此時，可以說新理論本身已異於單純應得的概念，而屬於新的應報理論。換言之，這意味著本模式本身不足以提供推導罪刑均衡之理論基礎，也無法通過本文的理論選擇基準。

三、公平分配模式

上述模式將犯罪人應經受不利益與犯罪間的關聯，置於直覺式的道德基礎上，致未能限定該不利益之範圍。針對此問題，接著說明的公平（fairness）分配模式則是嘗試透過整合分配正義與應報正義二者，藉由分配正義的思考來充實「應得」之內涵，試圖將刑罰施加不利益之範圍限定於與犯罪相關之範圍內，進而推導出罪刑均衡的結論。事實上，以最高法院105年度台上字第984號刑事判決為例，即有提到量刑實務中的應報內涵並非同害報復，而是意指基於分配正義，對於不法侵害行為給予等價責任之刑罰。雖然分配正義究竟如何與應報概念整合，該判決並未有更具體的說明，但已顯現出整合二者的思維在我國並非首見而具有討論價值。另外，國內也有如謝煜偉持否定論點，認為分配正義關係到的是社會中財富、資

源或權利之平等分配，涉及市民間如何分配共有、共享之物，故主張並沒有人會認為刑罰等苦痛是市民間的分配問題，認為應完全使用應報正義而非分配正義之概念¹¹⁷。誠然，此論點在將分配對象限定於「苦痛」的脈絡下或有其道理。但是，若將分配對象轉為「社會生活中可合理享受之利益」，而將刑罰視為利益調整手段時，則有既符合此論點對分配正義適用範圍的設定，且同時有將分配正義與應報概念整合之可能。由於本段欲分析之公平分配模式正是採取這樣的整合方向，考量對我國理論與實務有帶來啟示之可能，故納入本文對話範圍。

回到對本理論內涵之說明，此模式嘗試整合分配正義與應報正義之作法，是由公平分配社會中利益（benefit）與負擔（burden）的視角，來證立犯罪人因其犯行而應承受懲罰的正當性依據¹¹⁸。此內涵由Hart所指「當一群人為某種目的而結合在一起，根據規則限制其自身之自由時，那些願意接受限制的人有權利要求那些因為他們所受之限制而受惠者，也同樣遭受限制」之內容來看¹¹⁹，可理解為「限制的相互性（mutuality of restrictions）」¹²⁰。接續John Rawls的發展：「假設有一個互惠且公正的社會合作體系，只有當每個人或幾乎每個人都願意合作時，這個體系才能為大家帶來益處。假設此體系所要求的合作，意指每個人須付出一定的犧牲，或至少承受一些對自由的限制。又假設此合作體系所帶來的益處，在某程度上是免費的：亦即此合作體系是不穩定的，任何人即使未盡義務仍可透過其他人的合作而享受益處。在這些條件下，一個接受此體系產出益處的人，必須受到公平遊戲義務的拘束，不可拒絕合作來占他人便宜」，此內涵也被稱為「公平遊戲原則（the principle of fair play）」¹²⁰。

117 謝煜偉（註56），頁158。

118 RYBERG, *supra* note 102, at 36.

119 See H.L.A. Hart, *Are There Any Natural Rights?*, 64 PHIL. REV. 175 (1955).

120 John Rawls, *Legal Obligation and the Duty of Fair Play*, in COLLECTED PAPERS OF JOHN RAWLS 117, 123 (Samuel Freeman ed., 1999).

不過分配正義的觀點要如何與應報正義整合，亦即刑罰在平等地分配利益與負擔的連結中應扮演何種角色，仍有待進一步說明。對此，若由Herbert Morris的觀點來看，刑罰是在利益與負擔的不平衡發生時，扮演回復平衡的角色。申言之，其認為法律劃定了每個社會成員的權益範圍，一方面成員在該範圍內可享有不受他人侵犯的利益，另一方面成員遵守規範、承受負擔，自我節制（self-restraint）侵害其他成員權益來獲取利益的傾向，進而促成前述利益之達成與塑造出一個合作互利的體系。但是，犯罪人在享受其他成員遵守法律所獲致之利益的同時，卻拒絕作為守法的成員來接受對其行為加諸限制之負擔，因而享有比其他成員更多的額外利益。此時，此犯罪人可謂對社會負擔一筆債務，而刑罰所追求的正義就是透過使這位社會成員承受刑罰之負擔來償還該債務，進而回復利益與負擔間的均衡¹²¹。故刑罰可說是用來達成回復利益與負擔間平衡之目的的手段。依此理論，量刑時刑罰的嚴厲程度勢必也對應於利益與負擔間的均衡被干擾的程度。在此脈絡下，公平模式可謂透過以下四項命題來推導出罪刑均衡：（一）犯行嚴重性反映了利益與負擔間不均衡（下稱：不公平利益）的程度；（二）利益與負擔間被犯罪所干擾的均衡越多，為了回復公平的均衡所要求的負擔也越大；（三）刑罰的嚴厲程度反映了負擔的程度；（四）故當犯行越嚴重，即應接受越嚴厲的刑罰¹²²。

當犯罪所象徵的不公平利益程度越高時，作為平衡該不公平利益而施加之負擔的刑罰程度也會越高，故此推論中較無爭議者為命題（二）、（三）。唯一的質疑是犯罪所造成的不公平利益，是否必然要以刑罰為手段來加以平衡？例如犯罪人侵害被害人的財產法益而獲得不公平利益的狀況中，當現實上可使用回復原狀或損害賠償等

121 Herbert Morris, *Persons and Punishment*, 52 THE MONIST 475, 475-78 (1968).

122 RYBERG, *supra* note 102, at 38.

方式來使利益回復到平衡狀態時，採取刑罰是否仍屬必要手段¹²³？若答案為否，則命題（二）與（三）的存立即有商榷的餘地。不過，本文認為此質疑可能誤解此模式中所謂不公平利益的內涵，進而將調整該利益平衡的刑罰與填補損害的賠償混為一談。事實上，此模式認為犯罪人所獲致的利益，並非從被害者處所獲取且可透過賠償來加以填補的具體利益，而是由基於合作互惠的整體社群觀點所認知的「免於承擔社會成員為享受遵守法律之利益，所應共同承受之限制、負擔」的利益。此種不公平利益無法透過金錢賠償，而僅能透過刑罰剝奪犯罪人自由、使之負擔不利益，來進行調整與回復利益的平衡¹²⁴。

上述理解下，命題（二）、（三）與（四）間的推論，應無疑義，故本文聚焦於推論過程中爭議最大的命題（一）。該命題得否證立，繫於如何回應不公平利益的程度應如何認定，以及應如何推導出該程度與犯行嚴重性間之關係等疑問。而在這些疑問背後，核心問題則在於「不公平利益的內容與組成為何」。對此，Richard Dagger認為：雖然各個社會成員對於「特定法律」的感知有別，對於克制殺人與逃漏稅之傾向的難易度不同，故對禁止殺人與逃漏稅之限制，所感受的負擔也有別。惟因本模式所談的社會中守法的成員們應承受者，並非此種受限於特定法律而感知的負擔，而是對一般性的法體系整體所感受到的負擔¹²⁵。故不論犯罪人所犯罪名為何，其違背的是法體系整體要求應遵守法律的限制，所獲得的是免於該限制之不公平利益。而此立場代表即是Dagger所言之「殺人與逃漏稅應為其不公平的犯行，接受相同程度的懲罰」。不過，這句

123 Herbert Fingarette, *Punishment and Suffering*, 50 PROC. & ADDRESSES AM. PHIL. ASS'N 499, 502 (1977).

124 Wojciech Sadurski, *Theory of Punishment, Social Justice and Liberal Neutrality*, 7 LAW & PHIL. 351, 361 (1989); Richard Dagger, *Playing Fair with Punishment*, 103 ETHICS 473, 478 (1993). 國內討論見許家馨（註23），頁240。

125 Dagger, *supra* note 124, at 481.

話並非意指殺人與逃漏稅應該簡單地接受相同的刑罰，而是在說明其主張的公平模式雖然可證立刑罰制度本身，但無法提供個案時不同犯罪人應承受何程度刑罰量定的判斷標準，故尚須配合其他理論來處理量刑的問題¹²⁶。

雖然Dagger的主張中，因每個犯罪人受整體法體系之限制與其獲得不公平利益相同，故無法證立命題（一），但其他同屬此模式的理論，仍存在證立該命題的可能。而證立成功與否，繫於能否妥善處理兩點推論上的挑戰：第一，究竟應如何理解犯罪人獲得不公平利益的內涵（挑戰一）？如Morris自犯罪人所承受的負擔係指守法而自我節制的角度出發，主張犯行嚴重性應由犯罪人所承受負擔之強度來決定。亦即，當犯罪人為特定犯行的傾向越強時，為了遵守法律、克制犯罪而須承受的負擔就越高，若為犯行時所免於承受的負擔與獲致的不公平利益也越大，此時應承受的刑罰程度也越高。不過，若考慮現實上多數人對較輕微的逃漏稅之犯罪傾向強於較嚴重的殺人時，犯罪人須克服之內在傾向的強度、應承擔之負擔與犯罪時獲得不公平利益，可能會是前者高於後者¹²⁷。這在量刑階段中，可能導致推論出與犯行嚴重性相反，殺人的刑罰程度應輕於逃漏稅的結果¹²⁸，而反於命題（一）的設定。第二，與犯罪無關的不利益是否影響量刑（挑戰二）？此模式雖然對犯行嚴重性與刑罰嚴厲程度間的連結，建立較詳細的論理依據，但因其仍著眼在不利益程度的分配與調整，故勢必要面對與單純應得模式類似的問題。亦即，當刑罰程度是由犯罪人額外獲得不公平利益（或免於自我節制之負擔）所決定時，是否可將犯罪人經受與犯罪無關的不利益或負擔扣除，進而減輕刑罰程度。此問題的答案將決定與犯行

¹²⁶ *Id.* at 484.

¹²⁷ RYBERG, *supra* note 102, at 38; R. ANTONY DUFF, TRIALS AND PUNISHMENTS 213 (1986).

¹²⁸ Richard W. Burgh, *Do the Guilty Deserve Punishment?*, 79 J. PHIL. 193, 209 (1982).

嚴重性無關的因素得否影響量刑，進而確定能否證立命題（一）。

針對上述兩點挑戰，Wojciech Sadurski與George Sher的「額外自由（extra liberty）理論」則嘗試透過詮釋犯罪人所獲得額外利益之內涵來解決。二人並不以犯罪人為克制對犯罪行為的內在傾向而為之心理學意義上的自我節制，作為其負擔的內容，故其免於承擔負擔所獲得的額外利益與相應的刑罰程度，自然也不是以該內在傾向與自我節制的強度來判斷。相反地，二人主張犯罪人獲得的不公平額外利益，來自於當其他人認真看待法律上禁止的要求而被限制部分自由時，犯罪人違犯該要求而擺脫道德意義上的限制（moral restraint），所獲得之額外自由，亦即相比他人取得更多的行動選項與選擇可能¹²⁹。以殺人與逃漏稅為例，當違犯情節較重的殺人罪時，因該犯罪侵害法益程度較高，法規範強度較大而對行動自由設定較強限制，故觸犯該罪時所迴避的禁止程度較高，額外獲得之自由也較大，自然應獲得更嚴厲的刑罰¹³⁰。

在將犯罪所得不公平利益解讀為獲得額外行動自由的脈絡下，由於刑罰代表的是一種通常不被允許、剝奪犯罪人應得之保護的行為，具有限制其行為選項與行動自由的性質，故可與犯罪人獲得的額外自由相比較，進而影響量刑¹³¹。反之，由於刑罰和犯罪人經受之與犯罪無關的不利益（如：罹病、受傷）間，存在性質的差異，故二者間即處於無法比較、換算的狀態，自然也沒有所謂尋求犯罪人經受不利益與犯罪人獲得額外自由間平衡的可能。與此相似，Sadurski也否定犯罪人經受的任何不利益皆有影響量刑的餘地，其主張僅與犯罪相關之不利益有可能影響量刑，而可自犯罪所獲得利益中加以扣除，進而降低獲得之額外自由程度與相應承受的刑罰輕

129 Sadurski, *supra* note 124, at 357.

130 GEORGE SHER, DESERT 82 (1987); Wojciech Sadurski, *Distributive Justice and the Theory of Punishment*, 5 OXFORD J. LEGAL STUD. 47, 56 (1985).

131 SHER, *supra* note 130, at 84.

重¹³²。在此意義上，此理論相較於單純應得模式，可謂較成功地回應（挑戰二）。但此理論是否也能成功回應（挑戰一），才是本模式得否存立的關鍵。

確實，相較於Dagger直接承認無法將其理論適用於量刑階段，抑或Morris的理論推導出刑罰輕重無法對應犯行嚴重性的結論，額外自由說透過將犯行嚴重性連結到法規限制的強度，進而連結到違犯者獲得額外自由的程度，來說明為調整個案中犯罪人獲得的不公平利益，作為調整手段之刑罰的程度應相應改變，可謂最成功地論證命題一與證立罪刑均衡的嘗試。話雖如此，基於兩項理由，本文認為其仍未能成功作為推導罪刑均衡之基礎。第一，如Ryberg的觀察，本理論以擺脫道德意義上的限制所獲得額外自由來理解不公平利益之內涵的前提下，將導致此理論對概念內涵並非道德意義的法定犯罪，欠缺解釋力。申言之，法定犯罪（*mala prohibita*）中存在缺少法定禁止的狀況下並非不正行為之類型，由於此時並非加諸道德意義上之限制於守法者，故不會產生此理論定義下的額外自由，導致無法施加懲罰¹³³。為避免此困境，可能的解釋是認為「違犯法律本身」就是不道德的，進而將所有法定犯罪轉化為自然犯罪（*mala in se*）。但如此一來，將導致所有法定犯罪所違犯者是相同的道德上限制。由於該限制對守法者來說都是相同程度的，故只能平等地對所有法定犯罪量定同等的刑罰。本文認為這樣的詮釋並不現實，且忽略法定犯罪間由於侵害法益不同及立法政策考量等因素，勢必會在立法上與個案量刑中發生刑度上差異。此外，透過本質上並非法定犯罪內涵的社會道德違反來重新詮釋其意涵時，可謂是忽略法定犯罪的本質，根本地否定此犯罪類型的設定目的與存在。

132 WOJCIECH SADURSKI, GIVING DESERT ITS DUE: SOCIAL JUSTICE AND LEGAL THEORY 230 (1985).

133 RYBERG, *supra* note 102, at 43.

第二，除上述缺陷外，本理論將犯罪人獲得之額外自由作為其取得之不公平利益，將異質性且多樣化的犯罪類型化約為「額外自由」之單一概念，此論點有值得商榷之處。如R. Antony Duff就批評此理論的問題在於將各種犯罪行為的特質，都嘗試透過抽象性、形式性的理論來說明¹³⁴。首先，自由在概念上是否必然等同利益，就是值得詳加推論的部分。擁有更多行動選項確實代表享受更大的自由行動空間，但不同行動選項未必一律利大於弊，而是存在不同利弊得失的差異。以犯罪來說，雖然犯罪行為人獲得做一件被禁止行為的額外自由，但在極大化自我意志實現的同時，犯罪人也可能產生罪惡感、與親人及社群的疏離。誠然，部分犯罪人可能衡量後依然覺得犯罪是利大於弊，但在各個犯罪人擁有不同價值觀的前提下，能否一概而論增加犯罪的行為選項對每個人來說必然是一種利益，恐有疑義。接著，當我們說犯罪人獲得的行為自由是額外的利益時，這句話是建立在與遵守法律限制的守法市民間的比較上。換言之，必須其他人也感受到被法律限制不能為特定行為是一種不利益時，犯罪人違犯法律才能理解為獲得額外利益。但是，以殺人或強制性交等情節重大的類型為例，對守法市民來說，這些犯罪確實代表一種被限制而不可為的利益嗎？還是這些行為因為侵害法益重大或嚴重違反道德情感，縱然法律不設限制，其實多數市民也不會為之？若答案是後者，則是否仍可將這些行為的犯罪人認知為獲得額外的利益，即值得懷疑。

事實上，上述批評都指向此模式的根本問題：討論刑罰量定的基礎時，過於偏重不利益輕重調整的面向，忽略刑罰本質中不利益與非難傳遞間的關係。亦即，當刑罰本質包含對犯行傳遞非難評價，而量刑無可避免帶有對犯行之道德判斷時，量刑判斷的重心勢必包含對不法行為與結果嚴重性的道德判斷，以及如何將該判斷對

¹³⁴ DUFF, *supra* note 23, at 22.

應到刑罰量定。但是，此模式把討論重心放在利益分配與調整，將犯罪單純化約為不公平利益，將刑罰量定僅視為調整利益平衡的觀點，導致其必然忽略犯行異質性與對其非難所牽涉的複雜道德判斷。而在犯行嚴重性、可非難性恰好是命題（四）中罪刑均衡之核心關懷的狀況下，也註定此模式難以賦予推導出該結論之理論基礎，自然也難以符合本文理論選擇的基準。

四、表現與溝通模式

屬於此模式的應報理論，不再僅關注刑罰本質中被告承受不利益的面向，也同時關注非難傳遞及其與不利益間的關係，並據此推導罪刑均衡之結論。由於當代應報理論作為對矯治主義的回應，係以使犯罪人作為主體來為其理性自律選擇之犯行負責為中心，故勢必要犯罪人知曉其做了具負面性質之行為，其對該錯誤行為的回應才有被評價為負起責任的可能，故對其傳達犯行受負面評價之非難訊息，應可謂對其施加不利益以使其為犯行負責的必要要素。同時，由於非難傳遞係以傳達負面評價為內涵，其勢必強調作為傳遞對象之犯罪人係能夠理解規範意涵而共存於社群之市民，這也與當代應報論強調犯罪人為主體之論點相契合。因此，在此模式中刑罰並非單純的惡害，也不是追求犯罪預防的工具性手段，而是將犯罪人視為犯錯者，對其犯行傳達譴責與不認同之回應¹³⁵，具有象徵性的重要意涵¹³⁶：告知犯罪人其已為禁止且不被允許之行為，且該行為為應被公開譴責與非難¹³⁷。借用Robert Nozick的分類，依傳達或溝通行為目的之有無，此模式可再分為目的式（teleological）與非目的式（non-teleological）的應報理論¹³⁸：前者係指刑罰作為溝通行為，其目標不僅是傳達非難訊息，還包括使犯罪人接受（accepting）

135 VON HIRSCH, *supra* note 77, at 17-18.

136 Feinberg, *supra* note 20, at 98.

137 RYBERG, *supra* note 102, at 20.

138 ROBERT NOZICK, PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS 377 (1981).

該訊息後，受影響而發生道德上轉變，如Duff所持之溝通應報論，認為刑罰目的是使犯罪人悔悟罪行與改善自身¹³⁹；後者則非以此種轉變為目的，而僅是表現（express）非難訊息，使犯罪人了解（understand）該主張，如Andrew von Hirsch指出此理解下的非難並非引起特定情緒的工具¹⁴⁰。因此，本文稱此模式為「表現與溝通模式」。

根據對非難的一般性理解，應可合理推論當犯罪越應受責難時，犯罪人應受越高程度的非難。又此模式各理論的共同特徵是將刑罰理解為對犯行之非難，且該非難的程度可謂是由刑罰嚴厲程度來表現，故應可推論出「當犯行越嚴重時，刑罰也相應更嚴重」之罪刑均衡的結論。如此一來，可將此推論過程以下述命題來呈現：（一）國家對禁止行為施加制裁時，應採取刑罰的形式來表達非難、譴責；（二）當刑罰越嚴厲時，代表譴責也越嚴厲；（三）刑罰應依犯行可非難性、嚴重性來進行量定¹⁴¹。

而在此推論中，有待釐清者為命題（一），其得否證立取決於是否能充分說明：為何對犯罪表示非難仍須透過刑罰形式，以施加不利益的形式而為之。具體來說，當我們要表達對某人的讚許或譴責時，其實可以僅透過文字或言語來表達，未必需要給予具體獎勵或施加具體損害。惟若我們採取將刑罰看作表現或溝通的立場時，在刑罰本質包括非難傳遞與嚴厲處遇的前提下，可以說我們在嘗試透過非純粹言詞的具體手段來與犯罪人溝通。對應於刑罰本質，此溝通可謂包含兩個處於緊張關係的宣稱：其一是對應於非難傳遞的「應與犯罪人溝通我等非難之意」；其二是對應於嚴厲處遇的「犯罪人應被具體施加懲罰」。此時，在透過刑罰與犯罪人溝通的過程

139 DUFF, *supra* note 23, at 106.

140 ANDREW VON HIRSCH, CENSURE AND SANCTIONS 10 (1993).

141 RYBERG, *supra* note 102, at 21.

中，該施加於犯罪人之嚴厲處遇的角色與內涵為何，就成為須釐清的疑問：若只要傳遞非難訊息使犯罪人知曉即可完成溝通，則嚴厲處遇的功能與意涵為何？若需要嚴厲處遇才能完成溝通，其功能與意涵又為何？不同於單純應得模式中，基於犯錯者應經受不利益的觀點，刑罰必然包括對犯罪人施加之不利益。當本模式以應使犯罪人知曉對其犯行之非難的論點為基礎時，嚴厲處遇施加的功能、意涵及其必要性，都成為待釐清的關鍵課題。而且，當量刑就是在決定嚴厲處遇所施加之不利益程度時，嚴厲處遇存在的必要性及其意涵，都成為推導諸理論各自理解之量刑相當原則內涵時，須先處理的問題。

承上述，要使命題（一）成立，就要先說明當刑罰目的是傳遞非難訊息於犯罪人時，犯罪人為何仍應經受嚴厲處遇。唯有透過釐清嚴厲處遇的意涵及其與非難傳遞間的關係，才能充分證立命題一並推導出罪刑均衡之結論。目前，對此關係的討論可大略分為三種立場：訊息傳遞說、預防功能說與悔悟自新說。其中，預防功能說最廣泛的實踐正是國內也有主張的「應報的綜合理論」。而悔悟自新說正是許家馨所稱之「溝通應報論」¹⁴²，惟考慮到溝通應報論一詞其實可泛指所有以溝通模式詮釋應報觀點者，並不限於其所介紹以犯罪人表達自新為重點的看法，也包含犯罪人接受非難訊息但不悔悟之觀點，故本文為呈現其見解特點而稱之為「悔悟自新說」。由於皆為國內文獻論及之觀點，故皆為本文對話對象。至於訊息傳遞說則是本模式的最基礎類型，作為其他二立場之發展基礎，故也一併納入檢討範圍。

（一）訊息傳遞說

此立場通常為非目的式應報理論，施加刑罰不以使犯罪人轉變

¹⁴² 許家馨（註23），頁274。

為目的，而純粹著眼於刑罰傳遞非難訊息於犯罪人並使之理解的功能。在此脈絡下，嚴厲處遇主要扮演呈現、強化或輔助非難傳遞的角色。如有論者就主張當刑罰要使犯罪人理解其對犯行是確實地不贊同時，由於如文字等形式上的否定不足以使犯罪人理解，故應採取有形的否定來使之感受到非難訊息¹⁴³。亦即，將嚴厲處遇理解為犯罪人可理解的唯一語言，不利益的施加即是為使犯罪人可了解被傳遞之非難訊息。更白話地說，刑罰重要的是非難傳遞的功能，嚴厲處遇只是用來呈現、象徵該非難意涵的具體表現，自身不具獨立意涵。

不過，在考量犯罪人成立犯罪係以具有責性為前提的狀況下，撇開判決文字是否可使犯罪人理解其法學意涵的問題，假設我們只是要透過訊息傳遞來使犯罪人理解對其犯行的否定時，對具備理解能力與違法性意識才能成立犯罪的被告來說，法院只要透過適當的文字或言語諭知有罪判決，即應可達成此目的。此外，假若可類比有期徒刑的刑度，製作出對應犯罪可非難性的量表（如從1到10，殺人是10、竊盜是4），犯罪人即使未承受嚴厲處遇也可理解其犯行可非難性¹⁴⁴。換言之，筆者認為上述對犯罪人必經受不利益才能理解對其犯行之非難的預設，與現實恐怕是有所衝突的：可成立犯罪者毋須經受不利益也可了解非難意涵；無法了解受到有罪判決之非難訊息者，可能在刑法階層的檢驗中就難以成立犯罪。在此狀況下，此立場勢必要為嚴厲處遇的存在必要性，提出更具說服力的觀點。

對此，第一種觀點認為嚴厲處遇的意義在於使犯罪人透過實際經歷不利益，來確實地理解（*really understanding*）其加諸被害者之侵害與了解該行為應受非難。亦即，這種理解不同於只是單純被法官傳遞「該行為不可做」的譴責，而是透過確實承受不利益來感知

¹⁴³ J. R. LUCAS, ON JUSTICE 133 (1980).

¹⁴⁴ Günther, *supra* note 22, at 134.

其犯行所致侵害對於他人具有重要意義，進而真切地理解自身犯行的錯誤所在¹⁴⁵。不過，此看法的問題在於並未定義何謂真切的理解，對「要到何種程度才算真切的理解，其判斷基準何在」、「單純有罪判決傳遞非難跟讓被告實際經受嚴厲處遇對理解的影響有何差異」等問題欠缺明確答案。在標準不明的狀況下，如何由使犯罪人真切理解其犯行之錯誤的性質來推導出罪刑均衡之結論，也顯有困難。更甚者，若刑罰程度取決於犯罪人得否真切理解其錯誤時，勢必陷入量刑恣意與不安定的困境。

第二種觀點則類似於將刑罰看作一種要式行為，嚴厲處遇透過施加不利益的特定行動來確認確有譴責之意。亦即，一方面我們要傳遞適當的訊息於犯罪人，另一方面傳遞時要伴隨一系列相關連的行動，來確保確有傳遞該訊息內容之意¹⁴⁶。不過，當以此觀點來理解命題（一）時，如何連結到命題（二）並進而推導出罪刑均衡，就成為問題所在。首先，根據本模式推論中的命題（二），刑罰嚴厲程度取決於非難的嚴厲程度。假若嚴厲處遇施加不利益之程度取決於非難嚴厲程度時，若依本文前述將刑罰嚴厲程度理解為嚴厲處遇施加之不利益程度，或可推論出此結論。但是，由於此觀點將嚴厲處遇的性質與非難傳遞加以切割，其並未用來釋出非難訊息而僅是用來確保訊息傳遞是確有其意，故此時嚴厲處遇的不利益程度即與非難的嚴厲程度間欠缺論理上必然的連動性，而未必能推導出命題（二）的內容。另外，由於嚴厲處遇施加不利益之程度不必取決於非難程度，故也可設定一個特定數值的不利益程度來確保非難訊息傳遞的真摯性，而無需配合犯行嚴重性與非難嚴厲性來升高嚴厲處遇的不利益程度。此時，因刑罰程度無須對應犯行嚴重性，恐怕

¹⁴⁵ Igor Primoratz, *Punishment as Language*, 64 PHIL. 187, 199-200 (1989).

¹⁴⁶ Thomas Baldwin的比喻是對愛人表達愛意時，僅是適當的言語或書寫是不夠的，還必須用一些具體行動來確認其真意，如付出時間去證明其在意愛人更勝於其他事。See Thomas Baldwin, *Punishment, Communication, and Resentment*, in PUNISHMENT AND POLITICAL THEORY 124, 128 (Matt Matravers ed., 1999).

也難以推導出命題（三）中罪刑均衡的結論，無法符合本文設定之理論選擇基準。

（二）預防功能說

不同於將嚴厲處遇解釋為附隨於非難傳遞的見解，以下將目光轉向賦予嚴厲處遇獨立於非難傳遞之意涵的理論：「預防功能說」與「悔悟自新說」。此二理論除了對嚴厲處遇賦予獨立意涵外，也都將犯罪預防納入理論的建構中，差別在於前者是在應報理論的架構下承認犯罪預防得納入量刑考量，而後者仍堅持絕對應報論的立場，但承認基於應報所為量刑可能帶來教化等犯罪預防效果。本段中，首先以將嚴厲處遇理解為基於犯罪預防考量而存在的預防功能說作為分析對象。以可歸類為此理論的von Hirsch與Uma Narayan觀點為例，其認為不同於有罪判決的功能在於象徵性地傳遞非難，嚴厲處遇具有的是附加（supplemental）功能¹⁴⁷：在犯罪人知道犯行是錯誤的同時，提供其拒絕犯罪誘惑的務實動機（prudential incentive），實質上有透過嚇阻達成犯罪預防的功能¹⁴⁸。不過，與純粹嚇阻理論不同，此理論仍將犯罪人視為可理性溝通並應對犯行負責之主體，僅是面對人類意志的脆弱，故認為刑罰應附加嚇阻功能，提供其對抗犯罪動機的理由。因此，以對犯行非難作為優先考量的前提下，犯罪預防僅是作為應報框架下的附加考量因素，不得以其為理由而將刑罰程度提升至超過犯行嚴重性相對應的程度。換言之，根據此理論，由於僅合致於對犯罪非難之適當程度的嚴厲處遇才是被允許的，故刑罰程度應與犯行嚴重性合比例，或可推導出命題（三）中罪刑均衡之結論¹⁴⁹。

¹⁴⁷ Uma Narayan, *Appropriate Responses and Preventive Benefits: Justifying Censure and Hard Treatment in Legal Punishment*, 13 OXFORD J. LEGAL STUD. 166, 179-82 (1993).

¹⁴⁸ VON HIRSCH, *supra* note 140, at 12-14.

¹⁴⁹ VON HIRSCH, *supra* note 77, at 63.

事實上，此種試圖兼顧應報與犯罪預防觀點，故以對犯行之應報作為基礎框架，僅允許在該框架內追求犯罪預防效益的作法，即是國內所謂應報的綜合理論的特徵。由於此種理論是先以對犯罪之應報作為量刑基礎來形塑量刑責任的概念，在該責任所對應之宣告刑輕重（以下稱：責任刑）的上、下限範圍內，才考慮特別預防、一般預防等目的來修正責任刑程度，進而決定最終刑量。因此，此種理論能否成功推導命題（三）中罪刑均衡之結論與符合本文設定之理論選擇基準，取決於如何理解應報內涵及其與犯罪預防間的關係。申言之，在近代刑法所採的罪責原則已非「有罪必罰」之積極責任原則，而是「若無責任，則無刑罰」之消極責任原則的前提下¹⁵⁰，當罪刑均衡訴求刑罰程度應對應於犯罪可非難程度時，並非要求刑罰一定要百分之百對應於犯罪行為本身可非難的程度方屬正當。毋寧說，犯罪行為所對應之責任只是設定了限定法官量刑之框架，但並未否認在該框架內對宣告刑高低進行調整的可能。如此一來，當本理論模式基於應報觀點而要求刑罰程度必須對應犯行嚴重程度，且主張犯罪預防只能作為附加要素在對應應報意涵的刑罰程度框架內被考量與調整刑罰程度時，形式上可謂符合罪刑均衡之要求。話雖如此，當實質上最終刑度係帶有犯罪預防考量之性質時，是否仍可主張本理論實質上符合命題（三）中罪刑均衡之理念，非無商榷的餘地。

首先，本理論最關鍵的問題在於若認為量刑同時要追求應報與犯罪預防二目的時，應報與犯罪預防這兩個截然分立觀點是否有整合的可能¹⁵¹。詳言之，由於應報是回顧地評價過往發生之犯行，而犯罪預防是對未來進行預測，故各別透過二者來針對個案進行量刑

150 城下裕二，消極的責任主義の帰趨——わが国における近時の量刑理論の批判的検討，收於：川端博等編，理論刑法学の探究（2），頁31-32（2009年）。

國內相同理解：李茂生，（註22），頁107-108；王皇玉，（註15），頁54。

151 相同質疑：周漾沂（註6），頁283。

時所設定之刑罰程度原本就可能存在差異。因此，當二者同時作為量刑目的時，由於縱然施加於犯罪人的不利益程度被限定於與犯罪可非難性相當之範圍內，仍應以有效達成犯罪預防目的為要，故現實上即可能在個案中出現二者分別設定之合理刑罰程度間出現矛盾而未能同時兼顧二者之難題¹⁵²。例如若根據當事人之教化可能性，能有效發揮犯罪預防效果的刑罰程度並未座落於基於應報設定之責任刑範圍內，必須施加低於責任刑下限之不利益程度的嚴厲處遇方可達成預防再犯之目的時，此時應量定責任刑下限的刑度，抑或可預防犯罪的更低刑度？而此難題在承認可置於責任刑範圍內考量者包括內容相異的一般預防與特別預防時，由於必須再處理如何協調各目的間在量刑時之關係與兼顧其實現之難題，將導致問題複雜化而更難解決¹⁵³。

面對上述難題，雖然國內主張應報的綜合理論者並未有相關討論，但在日本實務主張量刑時首先應針對與犯行直接相關連的「犯情事由」進行判斷，決定與犯行可非難性間均衡的刑罰範圍後，在該範圍內基於對犯罪預防在內的「一般情狀事由」之考量來調整刑罰輕重並決定最終刑度¹⁵⁴，亦即同採此理論的狀況下，日本學界即出現可對責任刑範圍採較彈性理解之主張。亦即，雖然嚴格要求責任刑範圍的上限不得變動，但對下限採相對寬鬆的態度，再考量刑事政策與犯罪預防的狀況下，允許修正責任刑範圍之下限程度與量定低於該下限之刑罰¹⁵⁵。雖然此主張看似兼顧應報與犯罪預防，有

152 中村悠人（註45），頁182。

153 相似見解：中村悠人（註45），頁201。

154 遠藤邦彦，量刑判断過程の總論的検討，收於：大阪刑事実務研究会編，量刑実務大系（第1卷）：量刑總論，頁79（2011年）。

155 相關理論介紹：小池信太郎，量刑における犯行均衡原理と予防的考慮（1）：日独における最近の諸見解の検討を中心として，慶應法学，6号，頁35-38（2006年）。此外，英語世界也有主張對應於應報之責任刑範圍採「不對稱（asymmetric）」理解，允許量定低於責任刑下限之相似主張，see Richard S. Frase, *Limiting Retributivism, in THE FUTURE OF IMPRISONMENT* 83, 93-94 (Michael

效限定刑罰範圍以避免基於犯罪預防量定之刑罰由社會復歸轉為過苛的差異排除，同時仍可將犯罪人生活背景、成長歷程等特質與犯罪預防間的關係納入量刑考量。不過，就如有論者指出持此修正立場的多為主張基於犯罪預防之考量來量刑者¹⁵⁶，亦即並非以應報作為量刑基礎，而僅將其作為限制量刑輕重之上限，此修正立場實際上肯認犯罪預防相較於應報之優先性，故而允許刑罰程度實質上無需由犯罪可非難性來決定。如此一來，依此立場進行之量刑實際上可否論為符合罪刑均衡即有疑義，同時也無法避免基於犯罪預防來量刑時可能將犯罪人工具化之批評。更甚者，由於此觀點將量刑全然取決於預防考量，即可能無法免於過分重視與犯罪預防相關的行為人要素會侵害行為責任原則基本精神之批評¹⁵⁷。

在上述修正觀點依然無法解決難題的狀況下，筆者再次回到對本理論的檢討上。本文認為本理論最根本的問題，在於嘗試同時透過性質相反的回顧性應報觀點與展望性犯罪預防觀點來建構量刑相當原則。由於上述提及在理論上要融貫地整合二者來量定刑罰，同時又能推導出罪刑均衡之結論時，勢必遭遇難以兼顧二者的困境，因此另一個可能的解釋方向就是認為本理論單純是以應報為量刑目的，僅是容許透過犯罪預防之考量來調整最終刑罰程度。但是，這個解釋的問題是當基於犯罪人為過去犯行負責之應報思維，透過犯行可非難性來決定刑罰程度時，為何並非量刑目的且性質上全然相異的犯罪預防之考量，卻可用來調整犯罪人對過去犯罪負責之程度？換言之，此解釋顯然也無法迴避應報與預防在理論上難以融貫適用的問題，當然也無助於回應前述的各項質疑。對此，若回顧本理論植基於對矯治主義的關注，希望能將教化、社會復歸等預防考量納入量刑，進而透過考量行為人相關要素來調整刑罰程度之脈絡

Tonry ed., 2004).

156 井田良，*量刑理論と量刑事情*（註113），頁38。

157 謝煜偉（註38），頁184-185。

時，或可發現其實在迴避上述質疑的狀況下，仍有達成本理論發展目的之可能。首先，本文認為若考量到教化或社會復歸等效果主要取決於刑之執行的階段時，似可將這些考量置於如何進行刑之執行的判斷中¹⁵⁸，而非必然要在法官就個案量定宣告刑時進行考量。此外，關於調整刑罰程度的部分，事實上仍可能在不採取展望性犯罪預防觀點的前提下，將犯行相關的其他行為人因素與犯罪成因納入考量並透過量刑責任的層次來影響量刑，在維持理論一致性的前提下達到調整刑罰程度的效果¹⁵⁹。如此一來，是否仍有一定要在量刑階段採取應報的綜合理論的必要性，或有再商榷的餘地。

（三）悔悟自新說

不同於預防功能說將嚴厲處遇視為非難傳遞過程中，具有犯罪預防功能的附加要素，Duff所主張之悔悟自新說，亦即國內所稱之「溝通應報論」¹⁶⁰，則認為嚴厲處遇與傳遞非難訊息的有罪判決共同構成刑罰之溝通功能。此主張作為目的式應報理論，認為嚴厲處遇的存在不僅是為了使犯罪人了解非難訊息，還要使之接受該訊息，進而悔悟或自新¹⁶¹。亦即，刑罰作為世俗的贖罪（*penance*），犯罪人在接受非難訊息的傳遞後，透過承擔因犯罪而被施加的不利益來傳遞自身悔悟（*repentance*）、自新（*reform*）與和解（*reconciliation*）的訊息¹⁶²。

所謂悔悟，係指將犯罪人視作主體，使之透過承擔不利益，真摯地表達承認錯誤與歉疚之意¹⁶³。為了促成犯罪人悔悟的可能與使

158 相關理論介紹：蘇俊雄（註3），頁412。

159 代表性見解：謝煜偉（註38），頁193-194。

160 許家馨（註23），頁214。

161 DUFF, *supra* note 23, at 80-81.

162 *Id.* at 106.

163 R. Antony Duff, *Probation, Punishment and Restorative Justice: Should All Turism Be Engaged in Punishment?*, 42 HOW. J. CRIM. JUST. 181, 187-89 (2003).

之表達悔悟之意，刑罰所伴隨的不應只是瞬間的不利益，而須伴隨一定時間、代表犯罪人深刻地感受且經過思考的不利益¹⁶⁴。至於自新，係指將犯罪人看作主體，以使之充分悔悟與認知自身錯誤作為基礎，進而決定應如何改變自身¹⁶⁵。在此理解下，作為溝通的嚴厲處遇應使犯罪人理解其犯行嚴重性，並使之透過承受對應該犯行之不利益，來表達悔悟與自新之意。最終，正是在犯罪人表達悔悟與自新的基礎上，和解也才有達成的可能。不過，由於和解的促成須將犯罪人視為社群的一員，使其積極接受不利益的同時也避免承受羞辱¹⁶⁶，故嚴厲處遇的施加也應避免過度，須於與犯行嚴重性相對應的合理範圍內為之。在此脈絡下，Duff推導出刑罰程度須與犯行嚴重性合比例之要求，主張罪刑均衡之立場¹⁶⁷。不過，由於希望能促成與犯罪人的溝通，故Duff也主張在量刑時應保留考量其他要素的彈性，除主張在未不合比例的刑罰程度上、下限範圍內，皆可認為符合罪刑相當的要求外，也主張可基於對慈悲（*mercy*）之考量，當犯罪人已承受某些不利益時，衡量是否對犯罪人施加低於上述刑罰程度之下限的刑罰¹⁶⁸。

綜上所述，Duff將嚴厲處遇詮釋為「犯罪人承受與犯罪相對應不利益，進而表達其悔悟、自新之贖罪儀式」的論述，確實能夠推導出命題（三）中罪刑均衡之結論¹⁶⁹，同時可謂成功地迴避其他理論所面臨的困境：第一，不同於單純應得與公平分配模式，本理論並未過度重視不利益施加之面向而忽略非難傳遞的面向及二者的關聯；第二，不同於同模式之其他理論，本理論並未將嚴厲處遇性質

¹⁶⁴ DUFF, *supra* note 23, at 107-08.

¹⁶⁵ *Id.* at 108.

¹⁶⁶ *Id.* at 109-11.

¹⁶⁷ *Id.* at 132; R. Antony Duff, Was ist Tatproportionalität, und warum ist dieses Prinzip wichtig?, in: Frisch/von Hirsch/Albrecht (Hrsg.), Tatproportionalität: Normative und empirische Aspekte einer tatproportionalen Strafzumessung, 2003, S. 23 (27 ff.).

¹⁶⁸ DUFF, *supra* note 23, at 140-41.

¹⁶⁹ 許家馨（註23），頁256。

與犯罪人主觀認知或預測性之犯罪預防相連結，而是著眼於犯罪人透過承受不利益對外展現之意涵。在此意義上，其可謂堅守應報觀點的同時，也成功調和非難傳遞與嚴厲處遇二者。不過，本文認為此理論仍存在有待修正的問題。申言之，當Duff設定刑罰程度應對應於犯罪人為表達悔悟、自新而應承受不利益之程度時，該不利益程度是否必然對應於犯罪時的犯行可非難性，仍有商榷的餘地。亦即，假若依其結論，則量刑應是以犯罪人C決斷其犯行時點 t_1 為判斷其應承受不利益程度的基準時點，例如以C在 t_1 時的行為手段、法益侵害與主觀上故意等所呈現的犯行可非難性，判斷C應承受之刑罰程度。但是，當其設定刑罰程度要表彰個人悔悟、自新之意，就不能不面對因個體差異，每個人過往的成長歷程、生活環境所形塑的價值觀與事理判斷能力，以及這些因素與決斷犯行間的關聯性，都會決定一個人悔悟、自新的難易度，以及影響為表現悔悟及自新之意所應承受之不利益程度。換言之，假若考量C應承受的刑罰程度時，除了 t_1 時點的犯行可非難性外， t_1 之前的生長歷程與環境對犯行的可能影響也都有納入考量的必要，則與個人悔悟相關的人格要素也因而有被納入的可能，則刑罰嚴厲程度就不必然僅對應於犯行嚴重性而已。

承上述，本文認為Duff理論的思想基礎與其最終結論間，可能存在理論內在不一致的問題，亦即其關於罪刑均衡中犯行概念內涵與範圍的設定，與其理論基礎間有所衝突。確實，Duff可能也意識到此問題，故主張慈悲的考量可作為例外調整刑罰程度的事由，如肯定可以慈悲為由使犯罪人曾遭受的不利益成為量刑事由。但是，由於慈悲的內涵並不明確，加上其僅模糊地表示犯罪人曾遭受的不利益是基於慈悲可考量的事項，故當透過此考量來調整刑度時，雖然可能將與犯行相關的背景因素納入考量，但也可能將與犯行無關的不利益納入，導致遭遇類似單純應得理論的問題。換言之，本文

認為在此理論內在不一致的狀況下，是否如國內文獻主張可融貫地推導出罪刑均衡之結論，仍有商榷必要。

肆、本文立場之建構

透過上段的分析，可發現雖然當代應報理論皆主張可推導出罪刑均衡之結論，但各自推論中皆存在有待商榷的問題。在此前提下，以上述檢討為前提，筆者嘗試在本段中初步推導本文立場，並以之作為對各理論之回應。此推導過程中，首先將形塑出形式上得推導罪刑均衡之結論，且實質上可使犯罪人為其犯行負責並確保其主體性之應報觀點，接著依該觀點對嚴厲處遇意涵及其與非難傳遞間的關係進行詮釋，最終形塑合比例刑罰量定之意義，建構量刑相當原則與量刑責任之內涵。

一、本文立場之發展路徑

首先，筆者要從如何理解非難傳遞與嚴厲處遇的關係，來說明本文立場的發展路徑，亦即。由於在本文主張下，犯罪人承受刑罰時應居於主體地位，故應以獲知自身犯行的負面評價為前提，以承受懲罰施加的不利益作為回應該負面評價並負起責任的方式。因此，本文並不認為刑罰施加不利益僅是要調整犯罪人因犯行而獲得不公平利益的狀態，自難採取如公平分配模式的理論建構途徑。接著，同樣脈絡下，由於本文認為犯罪人應得之懲罰與不利益是作為理性主體來為其自主選擇的犯行負責，故自不認為承受不利益只是因犯行而須承受的報應。詳言之，當將刑罰施加不利益立基於「罪有應得」時，因偏重於描述不利益起因的面向，欠缺關於非難傳遞與不利益間相互關係的說明，自然也壓縮了以透過承擔不利益來回應非難並對犯行負責之觀點的發展空間。同時，由於產生犯罪人只是因為犯錯而單純作為載體來承擔作為報應之不利益的詮釋可能

性，也與本文設定犯罪人作為主體為犯行負責之基準有所扞格。正因如此，單純應得模式的理論建構方式並不適合本文。

正因為在本文立場的發展路徑中，將犯罪人承受刑罰施加的不利益，理解為具有回應犯行負面意涵並對犯行負責之意義，故不可只偏重於詮釋犯罪人承受不利益的面向，也同時須將作為主體來回應非難的部分納入討論。對照前述各理論建構模式，在筆者欲同時著重於詮釋非難傳遞與嚴厲處遇二者內涵與相互關係的前提下，表現與溝通模式中同時賦予二者獨立意涵的理論架構，可謂較適於本文。不過，由於在本文脈絡下，具有主體性之犯罪人並非單純接收非難訊息，而是以承受不利益來對犯行負責，作為對非難的回應方式，故發展路線可謂偏向溝通模式。亦即，嚴厲處遇在本文中，將被理解為不可分割地同時呈現「對犯罪人施加不利益來傳遞非難」與「犯罪人承受不利益來回應非難」兩種關係，形成相互傳遞訊息的溝通整體¹⁷⁰。另外，基於對應報的綜合理論的批判性立場，本文將嘗試推導以絕對應報理論為基礎，但同樣可將犯罪成因等納入量刑考量之論點。

綜上所述，同樣採溝通模式的悔悟自新觀點，似乎成為發展本文立場時較適合的對話對象。不過，正如前述對該理論之批評，以下也會指出本文對嚴厲處遇作為贖罪的論點，存在不同看法。換言之，雖然本文以溝通模式作為發展本文立場的出發點，且可能與悔悟自新觀點在某些面向具相似性，但筆者發展本文立場的推論內容，仍會與上述各理論間有所差異。以下，本文將先嘗試描述能形式上符合罪刑均衡且實質上可確保犯罪人主體性之應報意涵為何，並以該意涵為基礎來詮釋嚴厲處遇之意義，進而形塑出合比例刑罰量定之意涵。

¹⁷⁰ 許家馨（註23），頁255。

二、嚴厲處遇內涵之詮釋

（一）溝通模式下的應報意涵

由於採取溝通模式作為發展本文立場的路徑，故對非難傳遞與嚴厲處遇內涵的詮釋，自應以此模式為前提。不過，若在此前提下說明非難傳遞與嚴厲處遇的內涵與二者關係時，須先依序回應兩個問題：問題一，刑罰是否可能與溝通性質相容；問題二，若刑罰具溝通性質，則該溝通之實質內涵為何。

關於問題一，更詳細的提問是：當刑罰透過強制力侵害犯罪人權利與改變其法律上地位，故犯罪人並非主動且樂意去承受該不利益時，刑罰是否與溝通在性質上有相容的可能。雖然本文並非討論刑罰實際執行與施加不利益的階段，但法官裁量宣告刑既然是在量定最終施加之不利益，並以之而作為執行刑的基礎，自然應一併觀察。對此問題，假若將溝通理解為對話者雙方必須認識到彼此角色與相互間權利、義務關係，並在尊重彼此權利、義務關係的前提下，將彼此視為平等的對話主體，而非被強制或操縱的客體，基於真摯的意思對彼此間的價值衝突等推進對話時¹⁷¹，則刑罰未必沒有作為溝通一環的可能。首先，只是形式上由雙方地位不對等或使用強制手段就否定溝通性質的說法，實則忽略溝通原本就建立在社會成員彼此間的差異上，而此差異當然也包括身分、地位上之差異。同時，也忽略許多我們承認的溝通行為中，原本就可能存在權力關係及行使強制力的可能。毋寧說，判斷是否為溝通的重點並非有無強制力或意願如何，而是在於雙方對彼此權利、義務有無充分認知與尊重，以及是否維持雙方主體性，而未將對方視為可任意支配的

171 Kimberley Brownlee, *The Offender's Part in the Dialogue*, in CRIME, PUNISHMENT, AND RESPONSIBILITY: THE JURISPRUDENCE OF ANTONY DUFF 54, 57-58. (Rowan Cruft, Matthew H. Kramer & Mark R. Reiff eds., 2011).

客體¹⁷²。如此一來，當法官與被告雙方充分認識到彼此具有量刑權限與因犯罪而受量刑宣告之義務時，縱然雙方地位有別且法官判決具執行力而帶有強制性，只要法官是依法為論罪科刑之裁量，則應可認其並非將被告視為客體而任意剝奪其權利，而是在盡自身權責的同時，也將被告視為對犯行負責之主體，進而肯定刑罰量定具有溝通的性質。此外，若我們嘗試由「有意行動（intentional action）」的觀點切入¹⁷³，認為判斷某行為是否具溝通性質，除行為本身外，也應將該行為被實行的整體脈絡都作為推論的觀察對象時，若我們在包含審判過程的國家刑罰決定的整體脈絡下，將目光轉向國家進行刑罰量定時之意圖，並透過間接的證據與推論來獲得將刑罰理解為國家向犯罪人進行對話之確信時，刑罰實質上也有被理解為具備溝通性質的可能。亦即，若國家在運作刑事審判與刑罰量定的行動時，以賦予犯罪人充分論辯機會的形式來進程序，則我們或可預設國家是在認知與尊重彼此差異及主體身分的前提下，維持雙方有充分表達意見與形塑彼此權利、義務關係之機會，則刑罰量定自可能評價為與溝通性質相容。

肯認刑罰性質上與溝通有相容可能後，接著的問題二是將犯罪人承受刑罰理解為溝通的一環時，該溝通的實質內涵為何。一方面，對此內涵的理解反映我們宣稱基於應報觀點來建構理論時，如何理解應報意涵；另一方面，嚴厲處遇內涵也是由此推導而生。若

172 如指導教授與學生就論文寫作進行討論時，雙方存在師生身分差異且地位上不對等，指導教授也可能基於其權力來形構雙方討論形式、要求學生思考某問題或指示學生書寫的論述架構。但當雙方是認知彼此差異且相互尊重彼此權利義務關係來對話而維持學生主體性時，自可肯認論文指導的溝通性。

173 此觀點由Veronica Rodriguez-Blanco提出，目的在於解決Joseph Raz權威論與行本於益命題的不相容問題，典型例子是一個人要宣稱其較他人早起，該宣稱較容易被接受的理由，可能是此人早早就寢而不徹夜狂歡，進而有著與早起相關的融貫意圖，使我們相信他的早起宣言。See VERONICA RODRIGUEZ-BLANCO, LAW AND AUTHORITY UNDER THE GUISE OF THE GOOD 131-32 (2014)；國內討論：陳冠廷，法律規範性理論的「無心」之過？——以哈特與拉茲之理論為核心的反思，中研院法學期刊，27期，頁385-392（2020年）。

以Duff理論為例，當處罰者傳達非難訊息於犯罪人時，犯罪人透過承擔不利益所進行之溝通，實質意涵是對錯誤犯行的悔悟與改善自身。此時，將刑罰作為對過往犯罪的應報時，其內涵並非同害報復，而是使犯罪人表達悔意、追求自新的贖罪機制。由此可見，我們如何理解溝通模式下之應報意涵，會進而影響如何詮釋嚴厲處遇的內涵。如此一來，採取溝通模式發展應報理論時，應報可能呈現何種內涵，就成為須先行分析的問題。

對此，雖然筆者欲採取不同於Duff的理解來詮釋應報、溝通及嚴厲處遇的意涵，但在本文立場之開展路徑同屬溝通模式的狀況下，或可透過該理論，切入對溝通模式下應報可能呈現意涵之討論。事實上，當Duff從調解觀點（mediation）出發，將承受嚴厲處遇理解為針對非難訊息回應悔悟、自新訊息而帶有贖罪意義的溝通時¹⁷⁴，其理論中即可觀察到透過承受懲罰來追求和解或關係修復的應報意涵。即令如此，此時可能的疑問是：應報的概念內涵中，是否有容納和解意涵的空間呢？對於這個問題，從形式上的語義觀之，當今英語脈絡下的retribution確實指涉遭遇損害而施加懲罰的概念及在哲學文本中反映應受懲罰的理論，惟若回溯到拉丁文*retribuere*的意涵時，該詞除交換、回報外，也指涉債務返還之意涵。亦即，應報概念的發展原初，指涉的是對犯錯行為如何透過盡義務或支付酬報來彌補的一種債務與返還關係¹⁷⁵。在此意義下，將和解理解為對因犯罪所致法益侵害與人際關係變動進行修補時，其並非沒有被應報概念所涵括的可能。此外，當本文廣義地將應報理解為回顧地應對過去發生的犯罪時，針對因犯罪而變動的利益與人際關係進行修補的和解思考，自然有被安置在應報概念中的可能。

¹⁷⁴ DUFF, *supra* note 23, at 97-98.

¹⁷⁵ FASSIN (D.), *Punir: une passion contemporaine*, Paris, Seuil, 2017, p. 63.

事實上，國內引介的應報思想中，就存在從刑罰作為犯罪事後處理的視角切入¹⁷⁶，認為刑罰施加不利益是在積極進行事後處理，進而追求和解與人際關係修復的觀點。詳言之，採此視角的「犯罪事後處理理論」否定效益主義，認為追求犯罪預防僅會造成刑法機能的無限擴張與放棄針對個案擬定具體預防策略，導致刑罰成為嚇阻他人的工具¹⁷⁷，故基於回顧的應報觀點，主張刑罰功能應轉向對過去犯行所致的紛爭進行事後處理，具體修補人際關係與回應犯罪¹⁷⁸。亦即，刑罰的目的是要回顧地處理過往犯罪所致的侵害，在無法使用其他手段求得和解時，嘗試透過懲罰來修復被害者情緒或精神上損害¹⁷⁹，追求犯罪人與被害者可共同生活於社群中的可能。換言之，刑罰是作為緩起訴、和解與修復性司法等犯罪對應的一環，僅是在其他方式無法達成關係修復與和解時，才適用之最後手段¹⁸⁰，故當可用其他手段達成和解時則無須適用刑罰¹⁸¹。誠然，因犯罪事後處理的方式包羅萬象，致此理論核心的「事後處理」內涵模糊且指涉範圍不明：究竟是處理什麼、怎樣處理？惟若實質檢視此理論的理路，其核心精神可能並非告訴我們以何種手段處理犯罪，而是要指出應報思想未必立基於復仇或喚起懲罰慾望之情緒反應¹⁸²，而是存在以追求和解與關係修復為內涵的可能。在此理解下，若將透過刑罰進行的溝通理解為犯罪事後處理的一種和解式手

176 謝煜偉（註38），頁194-195。

177 吉岡一男，應報刑と謙抑主義，收於：京都大学法学部百周年記念論文集刊行委員会編，京都大学法学部創立百周年記念論文集（第2卷），頁511（1999年）。

178 謝煜偉，寬容社會的曙光？——從市民刑法的例外、犯罪事後處理機能、社會責任於個人責任的反饋回應三篇評論文，中研院法學期刊，17期，頁385（2015年）。

179 吉岡一男（註78），頁112。

180 吉岡一男（註78），頁207。

181 吉岡一男，刑事政策の展望，收於：アメリカ犯罪学と刑事政策，頁226-228（2008年）。

182 吉岡一男（註78），頁110。

段時¹⁸³，或可謂溝通模式的應報理論實則與此理論相似，都肯認以和解與關係修復為核心的應報意涵。

承上述，最終要思考的是本文採溝通模式發展的應報觀點中，是否也以強調紛爭和解與關係修復的意涵為基礎。對此，當將對犯行的應報理解為內含追求和解與關係修復的意涵時，由於犯罪人承擔嚴厲處遇並非僅是消極承擔同害報復帶來的侵害，而是希望透過不利益的承擔來回應非難訊息，積極表達承認過往犯行之錯誤與承擔應付的代價，進而修補犯罪所侵害之人際關係、與社群達成和解與使犯罪所生紛爭終局落幕。在此意義下，犯罪人可謂並非單純承受惡害之載體，而是透過不利益承擔來確立其作為主體並為犯行負起責任。同時，犯罪人在承受刑罰時勢必仍被對待為具有主體性的社群成員之一，其承受不利益方可傳達與社群和解與關係修復的訊息。綜上所述，可以說和解式的應報意涵應符合本文要求犯罪人作為主體為自己犯行負責之基準，可採納為理論建構的基礎。因此，本文以下將把溝通模式中之應報意涵理解為「對犯罪造成之侵害，在事後探究犯罪成因、嘗試了結紛爭、修復關係及和解」，嘗試進一步建構嚴厲處遇之意涵。

（二）作為代價承擔之嚴厲處遇

以上開推論為基礎，最終要來釐清嚴厲處遇之內涵。承受嚴厲處遇在溝通模式下被看作傳遞訊息、構成溝通的一環，但比起泛稱其為溝通，更重要的是具體指出此處溝通意涵為何，進而說明嚴厲處遇的意義。而為充實此論述，必須依序說明二點：第一，同樣採溝通模式，本文理解的溝通意涵與作為對話對象的Duff有何差異；第二，呼應本文對溝通與應報意涵的理解，應如何詮釋嚴厲處遇的內涵。對此，當有罪判決之諭知作為溝通行為，除再次確認被違犯

¹⁸³ 李茂生（註23），頁298。

規範之有效性外，同時也表達對被認定為犯罪人之否定評價時，其在現有法律規則體系下所確認的犯罪事實，即是犯罪人透過承受嚴厲處遇所要回應的對象。在此前提下，本文認為嚴厲處遇自身具有獨立於非難傳遞之意涵，且該內涵可透過與非難傳遞間的關係來理解¹⁸⁴。

首先，雖然同樣採溝通模式發展本文觀點，也肯定應報中包含和解的意涵，但筆者對於犯罪人承受嚴厲處遇來表達對犯行負責與促成關係修復的意思時，是否必然要表現出主觀上具有悔悟與自新之意，持不同意見。申言之，刑法作為以法益保護為目的之法規範，此透過立法程序所制定的行為規範本身預示了社群所肯認的價值，且傳達縱然不接受該價值也不應侵害的訊息¹⁸⁵。故當犯罪人透過犯行表達對該訊息的異議時，基於刑法中制裁規範而發動的刑罰，即是要對犯行傳達負面意涵的非難訊息，包括刑法保護的利益與價值，以及犯行非屬正當的理由。同時，犯罪人也透過承受刑罰帶來的不利益，作為對非難訊息的回應¹⁸⁶。但在可歸類為至善論(perfectionist)觀點的Duff理論中，當犯罪人承受嚴厲處遇來回應非難訊息時，其不僅是了解被懲罰的理由與刑法的保護對象，而是必須接受乃至於內化非難訊息所傳遞的價值，才可能真正表現出悔悟與自新的意涵¹⁸⁷。換言之，在將承受嚴厲處遇視為贖罪儀式的觀點下，與悔悟、自新連結的贖罪概念本身即帶有價值判斷，蘊含犯罪人主觀上承認自身價值錯誤的意涵¹⁸⁸。誠然，Duff的詮釋仍將承受刑罰的犯罪人看作可自主溝通的主體，但因本文主張尊重犯罪人與

184 相似看法：Günther, *supra* note 22, at 139.

185 但此價值並非不可撼動，且據此論知之判決與發動的刑罰正當性亦非無法被質疑。本文認為，我們仍可透過立法程序修法、憲法法庭解釋、一般法庭活動的價值辯證乃至於良心犯概念的適用等影響法律解釋，使隨社會變遷而生的價值轉變反映於刑法規範中。

186 Günther, *supra* note 22, at 132-33.

187 TADROS, *supra* note 89, at 78.

188 相似質疑：李茂生（註23），頁299。

社群主流價值之衝突，並將之納入負責與否的考量中，以便積極確立犯罪人主體性，故Duff對犯罪人針對犯行負責而承擔之不利益，須足以彰顯主觀上將刑法表彰價值內化於己之主張，應有修正必要。

對此，本文依然由犯罪人應作為主體為其犯行負責的立場切入，說明與Duff理論的差異，並進一步建構嚴厲處遇的意涵。在本文將應報理解為「對犯罪造成之侵害，在事後探究犯罪成因、嘗試了結紛爭、修復關係及和解」之意涵的前提下，當犯罪人作為主體為自身犯行負責而承受刑罰施加不利益時，該不利益的承擔可說是犯罪人對非難訊息進行回應，表達其肩負終局解決犯罪引發之紛爭及修復人際關係之責任，傳達追求和解與關係修復的訊息。不過，異於Duff主張犯罪人要面對價值上的錯誤並將刑法傳遞的價值內化於己，將其承受嚴厲處遇的意涵連結到個人主觀上悔悟與自省，本文採取多元論的立場（pluralism），認為犯罪人承受嚴厲處遇時，傳遞的訊息毋須具有主觀上贖罪與改變自身價值的意涵。亦即，雖然犯罪行為否定了刑法所欲保護的法益與彰顯的價值，但在尊重具主體性之犯罪人亦有自身堅持之價值的前提下，當犯罪人承受嚴厲處遇來回應非難訊息時，其毋須全盤接受並將刑法所傳達的價值內化於己身，而僅需了解到其具有不尊重其他價值的行為上錯誤，進而傳遞承認該錯誤與應認知、尊重其他價值的訊息。在此脈絡下，本文將承受嚴厲處遇進行溝通的意涵，聚焦在使犯罪人了解其未尊重其他價值的錯誤行為導致紛爭的前提下，於釐清犯罪成因與所致損害後，承擔與回應該客觀上損害，負起解決紛爭與修復人際關係之責任的面向上。簡言之，異於Duff將嚴厲處遇詮釋為贖罪，本文將其理解為紛爭了結與責任清算之機制。

申言之，筆者認為當犯罪人違犯刑法而侵害可謂是社群所共同承認的法益時，將使之與社群互動上形成緊張關係，犯罪在此意義上可被理解為一種紛爭的型態。在此前提下，當刑事程序中判斷國家可否施加刑罰權時，正是透過釐清犯罪成因與價值辯證，確立犯

行所代表的負面意涵與形塑要傳遞之非難內容。此外，當刑事程序以使犯罪造成的法秩序動盪與糾紛和平落幕為目的時¹⁸⁹，包括緩起訴、調解與修復性司法等刑罰替代方案，都呈現出使被告在具溝通性質的刑事程序中，知曉非難意涵並嘗試與社群達成和解及修復人際關係的面向。簡言之，針對具紛爭性質的犯罪，刑事程序不僅代表形塑、確立對犯行非難內容的過程，同是也是釐清犯罪成因並盡可能使犯罪人了解非難後嘗試和解、修復人際關係的歷程。事實上，最高法院108年度台上字第2191號刑事判決中，即揭示我國刑事程序包含修復性司法的精神，亦即司法除懲罰外也應包含撫慰、修復等功能，指出與上開論述精神相同的發展方向¹⁹⁰。在此理解下，本文認為應將刑罰與其他程序中刑罰替代方案一併放在上述使犯罪人負責並使之與社群修補關係的脈絡下，理解為促成和解的一環。詳言之，除社福機構、醫療單位提供加害與被害者諮商、治療與輔導等協助，在程序外促成和解及關係修補外，由於刑事案件最受矚目者依然是刑事審判與最終判決，故不應忽視在刑事程序與判決的過程中，透過各種刑罰替代方案來追求加害與被害和解，進而將和解精神反饋於社會、促成社會思辨與嘗試修補社會與犯罪人間關係的可能。至於論知有罪判決與施加刑罰，則可謂是在無法透過各種替代刑罰之和解與關係修復機制來了結犯罪所致之損害與紛爭時，作為了結紛爭與嘗試修補人際關係的最終手段。不過，若是如此，接下來的問題勢必是：在程序中替代刑罰之和解機制都失敗時，應如何理解作為最後手段的刑罰意涵，特別是其在了結紛爭與促成人際關係修復中的定位與意義。

189 林鈺雄（註13），頁10。

190 最高法院108年度台上字第2191號刑事判決，原文摘錄：「刑事司法理念，已從傳統的以刑罰作為中心之措施，轉變成修復式司法，亦即對於加害人、被害人及其等家屬，甚至包含社區成員或代表者，提供各式各樣之對話與解決問題之機會，使加害人認知其犯罪行為所帶來之影響，而反省其自身應負的刑責，並藉此契機，修復被害人等方面之情感創傷和填補其實質所受的損害。」

對此問題之回應，或可由類比同具紛爭解決性質的慰撫金來切入。誠然，由於民刑事程序本質上的差異，慰撫金與刑罰的決定程序、當事人參與程度有所不同。但是，若側重於慰撫金透過債務人付出賠償之代價來填補損害、慰撫進而使紛爭落幕的效果時，在本文將犯罪詮釋為犯罪人侵害被害人利益、社群秩序進而造成人際關係破壞之紛爭時，仍有透過了結紛爭的效果來類比二者的可能。亦即，或可將「犯罪人承受七年有期徒刑之不利益」，轉換詮釋為類似提出慰撫金的「犯罪人付出七年人身自由之代價」，將其理解為使犯罪人透過付出與紛爭相應之代價來傳達想了結紛爭之意，進而承擔使紛爭落幕、修補人際關係與促成和解之責任。接續此脈絡，或可將嚴厲處遇的內涵詮釋為在釐清犯罪責任後，當犯罪人窮盡手段仍無法透過調解或修復等手段，使紛爭在刑事程序中公開落幕及修復人際關係的情況下，針對犯行所致紛爭，透過類似清算程序的方式，以承受與該犯行相對應之刑罰所帶來權利剝奪之代價，表達其認知到實行犯行與不尊重他人所持價值之錯誤，並希望透過付出與錯誤對應之代價作為回應，在法律層次象徵該紛爭關係落幕，並作為未來尋求在現世層次達成和解與修復人際關係的基礎。同時，此種將犯罪人承受不利益理解為應答（answer）因犯行招致之非難及對責任進行清算的解讀¹⁹¹，亦即將承受刑罰詮釋為犯罪人回應犯行、了結責任之象徵，可謂符合本文將適度刑罰理解為犯罪人對自身犯行負起責任之基準。

綜上所述，不同於對過往犯行表達悔悟與贖罪的觀點，本文將犯罪人回應非難與承受嚴厲處遇的性質，理解為對過往犯行付出代價來追求紛爭落幕與修補人際關係¹⁹²，在責任清算的基礎上傳達尋

191 類似觀點 See R. ANTONY DUFF, ANSWERING FOR CRIME: RESPONSIBILITY AND LIABILITY IN THE CRIMINAL LAW 176-78 (2007).

192 透過承受嚴厲處遇來表達修補人際關係的意思時，可想見的修補對象包括社群與被害人。由於本文討論的是法益侵害所致糾紛與人際關係之破壞，故主要聚焦在犯罪人與社群間互動關係的修補上。不過，當犯罪人侵害作為保護

求未來和解可能之訊息，而可稱為「代價承擔理論」。不過，以此理解為基礎，如何進一步推論出量刑相當原則與量刑責任之內涵，則有待後續說明。

三、量刑相當原則與量刑責任之建構

最終，筆者透過處理以下問題，來建構量刑相當原則與量刑責任之概念內涵：一個問題是將嚴厲處遇理解為回應非難所為之代價承擔時，推導出之量刑相當原則內涵為何，另一個問題則是以此量刑相當原則為基礎，可形塑出何種內涵的量刑責任。由於二者具密切關聯性，故以下一併說明。

綜上所述，本文將犯罪人承受嚴厲處遇之意涵理解為：為回應對犯罪之非難，表達了解非難傳遞之訊息與對該錯誤犯行負起責任，進而嘗試了結紛爭、清算責任與修補人際關係之意思，故承擔代價。如此一來，既然接受嚴厲處遇來承擔代價是要對犯行負責，象徵代價之刑罰的嚴厲程度自應對應於其所要了結之紛爭的嚴重性，亦即其犯行之可非難程度。在此理解下，既然合比例刑罰量定之嚴厲程度應對應於犯行可非難性，故形式上可謂符合罪刑均衡之

客體之法益時，難免也會侵害被害人身體、財產等行為客體，故當犯罪人透過承受刑罰來修補與社群的關係時，可能也會涉及其與被害人間關係的修補，如透過賠償、和解來修補與被害人的關係時，可能同時促成與社群間的和解。話雖如此，由於被害人相較於社群，可能因個人利益遭侵害而有更強烈的復仇慾望或痛苦，故與社群和解時所需承擔的代價也未必與個人和解所需者等量齊觀，二者存在區分之必要。換言之，二者在人際關係的修補中屬於不同層次，但仍具有相互影響性：量刑主要考量的還是犯罪人為了與社群修補關係，須對法益侵害付出多少程度的代價，但其與被害人間關係的修補狀況（包括侵害類型及程度、修補方式與程度、雙方在社會中的階級與位置等考量因素），仍在一定範圍內影響應承擔代價的程度高低。例如在學說上即有當犯罪人願意對被害人賠償時，雖無法完全免除犯罪人刑責，但可在一定程度內產生減刑效果之主張（橫田信之，被害者と量刑，收於：大阪刑事実務研究会編，量刑実務大系（第2卷）：犯情等に関する諸問題，頁49-53（2011年））。礙於篇幅，當刑罰被理解為人際關係修補的手段時，犯罪人與社群、被害人的兩組關係修補在刑罰量定時的相互關係為何，將以他文獨立討論。

要求。至此為止，合比例刑罰量定之意涵，也就是量刑相當原則的意義暫時可理解為「刑罰嚴厲程度應對應於犯行可非難程度」。不過，在本文脈絡下，適度的刑罰量定除形式上符合罪刑均衡外，實質上亦應能維持犯罪人之主體性，故不同於前述各理論僅止於推導出罪刑均衡之結果，本文勢必要更詳細釐清作為對應對象的犯行可非難性，其意義為何。換言之，「刑罰嚴厲程度應對應於犯行可非難程度」中的「犯行」所指為何、如何理解犯行可非難性程度與犯罪人應承擔代價的高低等，會是建構量刑相當原則實質內涵，乃至於後續形塑量刑責任內涵時，必須釐清的問題。

如前所述，典型的罪刑均衡是透過犯行的不法性與有責性來決定其可非難性，進而要求刑罰嚴厲程度應對應該可非難性，並據此形塑出以（形式的）行為責任為內涵之量刑責任。不過，本文認為此種量刑相當原則與量刑責任可謂僅聚焦於犯罪人及其犯行本身，以一般理性人所具備的事理判斷能力與是否迴避犯行的能力為前提，判斷犯罪人在犯行時點的犯行可非難性。亦即，雖然此觀點在刑法犯罪階層中也會考量責任能力、違法性意識等要素，來決定有責性之有無及程度高低，據此判斷犯罪人須透過刑罰來應答非難之程度，但基於行為與罪責同時性原則¹⁹³，其僅聚焦於犯行時點與犯罪人個人能力，卻未注意各犯罪人所處社會脈絡可能作為犯罪成因乃至於影響犯罪人對犯罪負責之範圍。相對於此，本文將嘗試在正視現實上犯罪是由犯罪人實行犯罪行為所構成，而犯罪人是作為歸屬於社群中不同社會群體（social group）之成員而存在的前提上，嘗試將犯罪人與社群間多樣化的連結，納入理論建構的考量範圍，從承認犯罪人個人及其所處社會脈絡皆可能影響犯罪人對犯行負責程度的視角切入，建構不同於典型罪刑均衡內涵的量刑相當原則與量刑責任。以下，透過說明兩個問題，來初步建構本文立場。

¹⁹³ 王皇玉（註15），頁325。

(一) 問題一：應將社會脈絡納入本文立場建構的理由

首先，對問題一的說明將初步形塑出本文主張之量刑相當原則的樣貌。在本文中，犯罪人承擔之嚴厲處遇帶來的不利益被理解為回應犯行應承擔之代價，其目的在於表達使犯罪所致紛爭落幕及修補人際關係之訊息。而當犯罪人應承擔之代價是被放在犯罪人與社群和解的脈絡下理解、在修補關係的框架下被決定時，顯然地我們應從犯罪人與社群的相互關係中思考如何量定刑罰施加的不利益。亦即，既然和解是以犯罪人與社群的互動關係為基礎，則犯罪人所應承擔的代價不應只是單向度地對應於犯行的不法性與有責性，此時應捨棄僅以犯罪人與犯罪行為的兩面關係為基礎的思考路徑。相反地，在犯罪此糾紛不僅是犯罪人實行所致，也可能由犯行的背景脈絡所促成的前提下，除了因和解是建立在原因釐清之上，故決定以追求和解與關係修補為目的之代價時，有將可能為犯罪成因的社會脈絡納入考量的必要外，更重要的是我們在決定犯罪人應承擔代價時，應將「社群」放入原本僅由犯罪人與犯罪行為所構成的兩面關係中，在決定犯罪人為使紛爭落幕及修補人際關係而應承擔刑罰施加的不利益時，認知到不僅是犯罪本身嚴重性，犯罪人與社群間的關係也會對和解產生影響，故皆應被納入量刑考量中。

詳言之，我們不應忽略在犯罪人個人圖像中，其不僅是犯罪時進行決斷的個體，也同時作為不同社會群體之成員而生活於社會中。故當不同社會群體間存在社會資源分配之差異時，各犯罪人的生活環境、成長歷程也可能受該差異影響，進而成為其犯行的背景脈絡，並對其是否犯罪產生可能的影響。故若我們要思考犯罪人應以何種方式為犯行承擔代價及承擔代價之輕重時，既然是在使犯罪人與社群和解與修復關係的視角下進行思考，除了不停回溯追問被視為紛爭的犯罪的認定標準與成因外，也應觀察犯罪成因中犯罪人與社群的互動關係，如犯罪人生長環境之貧富良窳、是否獲得合理資源分配、社會保護網絡建構狀況、教育與成長歷程等與犯罪人相

關的社會脈絡（下稱：社會因素）是否對犯行發生有所影響¹⁹⁴。亦即，縱然具備有責性的犯罪人是出於對犯罪行為與法益侵害的充分認識，並基於個人自主決定而為犯行，但當承擔刑罰具有承擔代價、清算責任進而追求和解的意涵時，於決定犯罪人對其犯行應如何應答與承擔代價之際，勢必不應在釐清犯罪成因時忽略在直至其實行犯行前的人生歷程中，犯罪人背後的社會脈絡是否可能降低其行為決斷時的選擇可能性，或成為促成犯罪的原因。簡言之，只關注犯罪時的犯罪人特質，我們可能會做出「別人為什麼可以不犯案，你卻偏要犯案」的評價，唯有探究犯罪人形成犯罪決斷前在社會中的生命歷程跟生活背景，才能客觀評價其決定背後是否有選擇可能、是否有促成高度犯罪動機的壓力等，作為清算其責任與決定其應如何對犯行進行應答的基礎。

此時，假若判斷犯罪人係因在社會中處於弱勢與被壓迫的位置，致其在欠缺選擇能力的狀況下不得不實行犯罪時，若要求犯罪人仍須承擔百分之百對應於犯行嚴重性的代價來使紛爭落幕與追求和解，從犯罪人原本就與社群處於緊張關係的角度來看，並不合理。理由在於當自始該社群即與犯罪人處於衝突、壓迫的緊張關係，或更白話地說是社群自始就未與犯罪人處於和諧共存關係時，既然犯罪人無須對造成紛爭與緊張關係負完全責任，或可謂該社群對紛爭產生及緊張關係形成負有責任時，自不應要求犯罪人承擔起促成雙方和解的完全責任。在此脈絡下，當決定犯罪人應就犯行負責而承擔之代價，亦即量定刑罰程度時，除犯罪本身嚴重性外，自應將可能作為犯罪成因或與犯罪形成具關聯性而可體現犯罪人與社群間緊張關係的社會因素，皆納入量刑考量中。

¹⁹⁴ 以臺灣臺北地方法院109年度訴字第65號刑事判決為例，參照「參酌被告為五專後二年肄業之智識程度、未婚無子女、自陳現為職業德州撲克選手等生活狀況」之內容，可發現實務上雖未詳述對量刑產生影響的理由與方式，但形式上已肯定為刑法第57條明文規定的智識程度、生活狀況，以及非明文規範的家庭狀況、職業類別等可作為量刑事由，也提供本文論述具體實踐的可能。

另外，從適度的量刑即是使犯罪人居於主體地位為犯行負責的本文基準來看，將犯行背後的社會脈絡等納入考量也是合理的解釋。申言之，在承認犯罪背後的社會因素縱然不會直接招致犯罪發生，也可能導致犯罪人因欠缺行為選擇可能而間接成為犯罪成因的前提下，可以說社會因素無可避免地在清算犯罪人責任時是可能影響責任認定的事由。如Kate Warner曾提出相似觀點，認為澳洲原住民所遭遇的貧窮、欠缺教育與工作機會、政府政策所致社會與經濟上不利益，可謂是犯罪的社會背景，故主張應將之作為量刑事由，並認為量刑雖未能修復這些不正義，但至少可避免加劇社會與經濟不平等¹⁹⁵。不過，雖此意見與本文切入點相同，皆指出量刑時未考量社會因素會招致犯罪人處境惡化，但聚焦在未來不平等狀況的觀點與本文的回顧觀點有別。亦即，本文主要著眼於社會因素在犯罪人過去作出行為決定與選擇之歷程中的影響，認為犯罪人可能因社經地位不平等與壓迫，使其並非在百分之百選擇自由下作出決定，故不應在責任清算時將完整的責任歸由其承擔，並使其經受相應刑罰來對犯罪承擔代價。換言之，假若不在量刑時考量這些事由，而使犯罪人就犯行嚴重性負起完整責任時，可謂使之承受不相應的責任，不利益的施加不但無法被視為犯罪人對自身犯行負責所承擔之代價，甚至可說是使犯罪人額外承擔社會對促成犯罪應負的責任，造成對其施加過度惡害。此時，原本因社會因素而處於社會邊緣而與社群處於壓迫、排除等緊張關係的犯罪人，自非作為主體而在修補雙方關係與促成和解的脈絡下承擔適度的刑罰，反而是在緊張關係加劇或於社群中處境惡化的情境下被視作客體對待。

綜上所述，本文主張應將犯行背後的社會因素納入犯行可非難性的考量中，進而決定犯罪人應承擔之代價，亦即合比例刑罰量定

195 Kate Warner, *Equality before the Law: Racial and Social Background Factors as Sources of Mitigation at Sentencing*, in MITIGATION AND AGGRAVATION AT SENTENCING 124, 142 (Julian V. Roberts ed., 2011).

的程度。換言之，本文主張的量刑相當原則應理解為：刑罰嚴厲程度應對應於「從犯罪人與社會脈絡之關係來看，犯罪人具自主選擇可能性之範圍內的」犯行可非難性。亦即從社群與犯罪人間的關係切入並考量犯行背後的社會因素時，犯罪人僅對在該社會脈絡下具選擇可能而選擇實行之犯行負責，當犯罪人與社群處於非壓迫、非衝突的共存關係時，則透過承擔與犯行相應的代價來使紛爭落幕與尋求修補關係及和解的可能。反之，若犯罪人與社群處於受壓迫或緊張關係時，其最終透過承受刑罰來尋求關係修復與和解的可能時，犯罪人本身對其犯行所應付出之代價，即應扣除因社會因素導致欠缺選擇可能的範圍，而僅就自主選擇之範圍來承受刑罰加以負責¹⁹⁶。總結來說，若更細緻地描述上開定義，合比例的量刑係指立於一般理性人的角度，以該犯罪行為在犯罪時所具備之可非難性所推導出的刑罰程度為基礎，再從犯罪人個人的角度考量犯罪時點外可能壓迫、限縮犯罪人自主行為選擇之社會因素，對基礎刑度進行下修之結果。

（二）問題二：社會脈絡對刑罰量定影響性之證成

肯定社會因素應納入量刑相當原則之內涵後，最終要討論的是如何證成社會因素對量刑的影響性，以及進一步形塑量刑責任的性

¹⁹⁶ 本文是在犯罪人作為責任主體的脈絡下進行討論。但如前所述，本文認為針對犯罪造成的侵害與人際關係破壞，除犯罪人在刑事程序中透過刑罰替代方案或刑罰來尋求和解外，社群中也同樣存在程序外之和解機制。因此，可以說犯罪人與社群是各自作為責任主體，透過多種實踐方式一同進行人際關係之修補。犯罪人雖然作為社群成員而受社會脈絡影響，但類似於犯罪論中「修正的決定論」的想法，在社會背景影響下的理性個人不排除有做出自主選擇的可能，故犯罪人自有在其得自主選擇之範圍內承擔代價並尋求和解之必要，而刑罰與刑罰替代方案即是刑事程序中之實踐形式。同時，社群作為責任主體也可能透過社福、醫療等不同實踐形式，在刑事程序外透過較隱密、柔軟的方式展現追求和解的另一種實踐形式。至於社群中和解狀況是否會對個人透過刑罰承擔代價來追求和解產生影響，二者的相互關係也是值得探究的問題。惟因本文聚焦在刑罰層次之討論，此部分與本文主題相距甚遠，故暫不討論。

質與內涵。關於此討論，本文欲從兩個例子及檢討當代應報理論來思考：例一是貧窮且欠缺充分社福照護與技職教育的母親C₁為其幼小孩童偷取食物及冬衣¹⁹⁷；例二是有強制性交前科且接近邊緣性智能不足的C₂，自我內在支持系統、家庭支持系統、社會支持系統均不佳，且在受強制治療但未治癒之情況下出監，出監後未受監控輔導而再犯¹⁹⁸。若僅以犯行時點來觀察二案，除C₂智能不足影響其有責性外，刑罰程度似僅對應於其竊盜與強制性交犯行之可非難性即可。但是，二被告為犯行前，分別存在貧窮、家庭及社會支持系統不足、國家未提供完善治療等，可能構成社會剝奪（social deprivation）且可能促成乃至於支配被告最終犯行選擇的因素。若檢視當代應報理論時，不乏承認這些因素可納入量刑考量的觀點，其可大略分為二種推論取徑：1. 同情（compassion）觀點；2. 修正的社會應報論。前者認為該犯罪人之可非難性並未降低，僅是遭遇一般理性人不致犯罪的特殊狀況，故應基於對其之同情而降低刑罰程度¹⁹⁹。至於後者則採取相對的、交錯的責任觀，認為量刑責任是揉合法理論的責任及其之外的社會影響因素所形成，故社會因素有反饋於個人責任並作為減刑因素的可能²⁰⁰。以下，先透過對前者之批評，證立本文所採的量刑責任理論，再透過與後者的比較，說明採取本文理論的意義。

首先，同情觀點的基礎在於犯罪人因社會剝奪等因素而被置於困境中，進而在決斷是否犯罪時做出一般狀況下不會做的犯罪選擇。不過，關於如何證立社會因素對量刑之影響，又存在不同看法：如Duff從國家與社會責任切入，認為社會剝奪導致犯罪人並未受到法律應有之保障，故可視為犯罪人已被排除於社群與犯罪人的

197 DUFF, *supra* note 23, at 182.

198 改編最高法院102年度台上字第2575號刑事判決事實。

199 VON HIRSCH & ASHWORTH, *supra* note 34, at 65-70.

200 謝煜偉（註178），頁389-390。

溝通外，導致國家失去懲罰該犯罪人之資格²⁰¹。反之，von Hirsch 則從犯罪人遭遇的困境切入，認為國家與社會是否有責任並非重點，重點在於對持續遭遇社會剝奪的犯罪人投注同情，進而降低刑罰程度²⁰²。不過，雖然上述見解都觀察到問題的重點，但其推論各有不足之處。因此，以下筆者即搭配對二者的批評，證成社會因素對量刑之影響性。

承前所述，當犯罪人承受刑罰施加不利益係為了承擔代價進而修補人際關係時，既然刑罰程度是在犯罪人追求與社群和解的框架下決定，亦即透過思考犯罪人及社群各自與犯罪間的關係來決定量刑時，自應以犯罪人及社會各自對促成犯罪紛爭產生時所應負之責任為基礎，思考修補雙方關係及促成和解的最佳處理方式為何。換言之，除了使犯罪人承擔對犯行應負之責任外，假若我們肯認刑罰在建立社會連帶的同時，也是促成社會對犯罪發生進行自我批判與反省的契機時²⁰³，無疑地本文肯定在犯罪此紛爭發生的背後，可能同時存在犯罪人責任與社會責任²⁰⁴。並且，當刑罰量定是以開啟犯罪人與社群雙方了結紛爭、修補關係為基礎時，在和解須以雙方充分理解紛爭成因與自身責任的前提下，犯行相關事由及犯行背後的社會因素自應皆納入量刑考量中。話雖如此，本文並非以社群亦應對犯罪發生負起責任為由，來推導出社會因素可影響量刑之結論。換言之，與從檢討國家與社會責任進而限制國家刑罰權的角度，來建構社會因素影響量刑的論點不同，本文認為其過分偏重社會責任的面向，卻忽略犯罪人受社會因素之影響與量刑間的關連。本文認為當刑罰量定是綜合社會責任與犯罪行為責任來推導時，當然存在基於社會責任來限制刑罰權限與影響量刑的可能，但當此處討論的

201 DUFF, *supra* note 23, at 181-84.

202 VON HIRSCH & ASHWORTH, *supra* note 34, at 69.

203 顏厥安（註97），頁350。

204 類似見解：謝煜偉（註38），頁193。

量刑責任是以量刑相當原則為基礎所形塑，而量刑相當原則的內涵是犯罪人為其犯行承擔代價時，量刑責任即應著眼於犯罪人及其犯行來建構，即使犯罪紛爭是由社群與犯罪人所共同促成，量刑責任在本質上仍與社會責任分屬個別獨立、各自對犯罪發生負責之責任。亦即，本文仍欲由犯罪人為其犯行負責與承擔代價的層次切入，論證社會因素對量刑的影響性。

申言之，本文認為仍應回到犯罪人作為主體對犯行負責的基礎上，從其與社群間的關係來思考修補關係時應承擔之代價為何，並主張犯罪人只在受社會因素影響，但能力上仍具自主選擇可能之範圍內對其犯行負責²⁰⁵。也就是說，當考量犯罪人所處生長環境、受教條件、工作與生活狀況等社會因素，其處於受到社會剝奪之境況，且其對犯罪與否的選擇能力因社會因素影響而被限縮，例如欠缺不犯罪的可能或受迫實行犯罪時，犯罪人僅在其因社會因素影響卻仍具行為選擇可能的範圍內對犯行負責。理由在於，在此狀況下由犯罪人與社群間的關係來檢視犯罪成因時，社會因素可謂社群透過對犯罪人之影響來促成紛爭發生的事由之一，其透過影響犯罪人行為選擇而與犯罪實現產生連結，進而分擔了促成犯罪的一部分力度。同時，由犯罪人被社群所創造的社會剝奪所影響之關係來看，當紛爭起因於該社會剝奪等因素時，和解關係的破壞原本即非可完全歸責於犯罪行為，反而是這些社會因素自始就使雙方處於難謂共生共存的關係中，故自難在不考量社會因素的狀況下，要求犯罪人為修補關係，而失去主體地位及承擔不應由其完全承擔的代價。

而此論點與同情觀點的最大差異，就在於同情觀點未將社群扮演的角色納入建構責任的考量中，而仍將理論立基於各犯罪人皆為

205 持準應報基礎（quasi-retributive grounds）之論點，對非犯罪時點發生但可影響量刑的衡平要素（equity factor）賦予理論基礎之相似見解，see VON HIRSCH & ASHWORTH, *supra* note 34, at 175.

理性平均人的想像，以犯罪人為自身犯行負起完全責任為原則，僅在社會剝奪等狀況下，基於不明確的同情概念來減輕施加的刑罰程度。反之，本文捨棄理性平均人的想像，著眼於犯罪人與社群的互動關係，將所屬社會群體的差異可能導致資源分配不公與社會剝奪，造成壓迫個人實行犯罪與否之選擇等納入理論建構，進而在正視社會群體差異對個人影響力之前提下，主張犯罪人自始即應被限定於在社會因素影響下，仍可自主、非受迫選擇行為的範圍內，對犯罪負責。以前述例一來說，若C₁確定成立竊盜罪時，固然應為其不法且有責之犯行負起責任。不過，若將目光由竊盜犯行時點擴及於她所處的社會環境時（社會剝奪的狀況、背負獨力照顧孩子的壓力等），假定她是在必須獲得冬衣與食物來維持幼童生存的境況下，因社會環境而無法獲得維生資源才竊盜，由於社會因素可謂是促成該竊盜的強大壓力，該竊盜行為係於欠缺充分選擇可能下不得不為之時，應考量社會因素造成犯罪人受迫並促成犯罪的強度，降低對其非難與施加不利益之程度而減輕量刑²⁰⁶。

總結以上，本文是著眼於個人在社群中的位置，考量個人所處社會環境及社會因素與個人間的關係，進而判斷最終犯罪行為的選擇是否受社會因素影響及影響之範圍，主張僅在行為有自主選擇可能的範圍內承擔責任。因此，不同於人格或性格責任論，本文在將刑罰理解為犯罪人作為主體為「犯行」負責，否定將犯罪人客體化為「危險源」的預設下，並非著眼於社會因素對犯罪人惡性或內在人格危險性之影響來建構量刑責任²⁰⁷。換言之，本文並非聚焦於行

206 本理論的操作其實仍有具體問題需處理：第一，究竟是要社會因素與犯行間具有關聯性即可影響量刑，還是必須達到具因果性時才可，這會決定社會因素影響量刑的難易度。對此，若選擇後者時，縱使可說明社會因素與犯罪間的關聯性，如何推導二者的因果性會是須解決的難題（See Warner, *supra* note 195, at 141）。第二，若確定社會因素之影響性時，應如何決定減刑程度，有無可操作指標。不過，因本文目的是初步提出量刑相當原則的理論框架，故篇幅上難以回應這些問題，須留待它文處理。

207 確實，人格可作為社會影響個人行為之媒介，但本文認為與其設定此抽象概

為人內在的人格層次，而依然是聚焦於行為層次，基於犯罪行為可非難性來決定量刑。只不過，相較於僅單純由犯行嚴重性來決定刑罰程度的傳統行為責任論，本文多納入對犯行背後社會因素及其影響性之實質考量，從社群與個人相互關係中去釐清社會因素對行為的影響性，並肯定其對量刑之影響。在此意義下，本文對傳統行為責任論進行調整後之觀點，可稱為「行為實質責任論」。依此觀點，不同於典型罪刑均衡僅回顧地考量犯罪時點之形式的犯行可非難性，本文認為犯行可非難性應是以形式的可非難性為基礎，同時實質檢視犯行背後的社會因素乃至於國家、社會與犯罪人間潛藏的緊張關係對犯罪選擇之影響，進而認定犯罪人僅對自主選擇能力範圍內所為犯行具實質可非難性。於量刑時，則對應此實質可非難性，來決定犯罪人應承受嚴厲處遇施加之不利益的程度。

最後，雖然前述修正的社會應報論同樣採取將社會因素納入量刑考量的論述，但由本文採用的行為實質責任論的內容，也可看出二者的差異，以及採用後者的意義。申言之，修正的社會應報論由個人與社會在犯罪形成中的交互關係出發，透過屬於不同層次的個人責任與社會責任來建構量刑責任的嘗試，相較於同情觀點過度偏重社會責任的問題，可謂深具理論意義。不過，由於個人與社會間存在極為複雜的相互關係，故此理論實則存在一些有待釐清的疑問：究竟是何種相互關係的類型與互相影響的形式可證成減輕量刑的結果？若存在不同關係形式時，各類型推導減刑的論證是否相同？而這些疑問也反映於社會責任究應如何反饋於個人責任的質

念作為觀察對象並以之來決定犯罪責任，考量現今以個人作為社群中主體並以個人行為選擇為研究主題的行為科學或行為經濟學已蓬勃發展，透過實證研究來觀察社會中個人犯罪行為選擇並加以理論化的作法，或可使我們在決定犯罪責任時將目光重新聚焦於犯罪行為的層次。亦即，假若可釐清個人在不同變項的社會因素影響下可能的行為選擇時，即可透過此種研究成果來作為輔助判斷社會因素與個人行為間關係之基礎，而將責任判斷的重點直接放在社會因素與個人行為上。

疑²⁰⁸。相較於此，行為實質責任論將社會與個人間的相互關係，聚焦在社會因素對行為選擇的影響，由社會因素對個人犯行的促成來論述其在量刑責任中的位置，可謂較具體地指明社會因素影響量刑的理據。更進一步來看，雖然修正的社會應報論承認社會因素可作為量刑減輕事由，但也承認社會因素可能扮演加重量刑的角色²⁰⁹。若是如此，在理論的層次上，當本理論並未清楚說明有關個人與社會相互關係的上述疑問時，就無法排除基於社會因素而加重量刑的可能。此時，是否可能因社會因素而量定高於個人行為責任的刑罰，或是否可能使法官在實際操作上有偏向加重而忽視減輕的狀況，都有再討論的必要。相對於此，行為實質責任論由於設定以行為責任為量刑的基礎框架，並將社會因素的影響性聚焦在對個人行為選擇的影響上，故具有確保社會因素僅可能減低刑罰程度，進而明確限定刑罰程度於行為責任範疇的優點。

伍、結論

綜上所述，在作為對話對象之我國理論發展係以應報為主的脈絡下，本文同樣選擇以應報為量刑目的來建構量刑相當原則與量刑責任（本文「貳」）。不過，由於當代應報理論百家爭鳴，故本文在將應報觀點下適度的量刑理解為形式上符合罪刑均衡且實質上維持犯罪人主體地位的前提下，與當代應報理論中較重要且為國內文獻論及者進行對話，透過對這些論點的分析與批判，嘗試形塑本文立場（本文「參」）。依本文立場，在將應報意涵理解為「對犯罪造成之侵害，在事後探究犯罪成因、嘗試了結紛爭、修復關係及和解」的前提下，本文將犯罪人承受嚴厲處遇之意涵理解為：為回應對犯

208 顏厥安（註97），頁351-252。

209 謝煜偉（註178），頁389-390。

罪之非難，表達了解非難之訊息與對該錯誤犯行負起責任，進而嘗試了結紛爭、清算責任與修補人際關係之意思，所承擔之代價。基於將嚴厲處遇為承擔代價之觀點，本文主張應將社群與行為人、犯罪的關係納入思考，建構「刑罰嚴厲程度應對應於犯罪人在與社會脈絡之關係中具自主選擇可能性之範圍內的犯行可非難性」為內涵之量刑相當原則。最終，依據此量刑相當原則之內涵，本文提出除犯罪行為本身外，也應將犯行背後社會因素及其影響性納入實質考量之「行為實質責任論」(本文「肆」)。

未來，在我國法官係適用刑法第57條來針對個案量刑的前提下，筆者將嘗試以建構的量刑相當原則與量刑責任為基礎，詮釋該條文中各要件之意涵與要件間的關係，以將該條文形塑為可為我國法官適用之量刑準則為目標。至於此目標的詳細發展，自非本文篇幅所能處理，故以下僅先初步勾勒出可能方向。首先，針對該條中「行為人責任」與「一切情狀」等部分，對照上述行為實質責任論之內涵，或可將作為量刑基礎的行為人責任，理解為傳統意義下的形式的行為責任，亦即不考慮行為背後社會因素，單純考量犯罪時點下犯行可非難性所對應的責任。接著，雖然條文未明示「應審酌之一切情狀」的特徵或範圍，但應可理解為不限於犯罪時點所發生者，包含一切與犯罪形成相關或可能影響犯罪人可非難性的要素(但不包括犯罪預防考量相關要素)。最後，針對該條羅列十款的「尤應注意事項」，則可依其性質將其歸類為偏向行為人責任或一切情狀，並依照本文建構的理論充實各款項內涵與判斷標準。此外，也可思考是否有在筆者理論下，將前科、國家違法偵查等非明文列出之事項納入量刑的正當性與可能性。

參考文獻

1. 中文部分

- 王皇玉（2009），論刑罰的目的，收於：刑罰與社會規訓——台灣刑事制裁新舊思維的衝突與轉變，頁1-34，臺北：元照。
- （2020），刑法總則，6版，臺北：新學林。
- 李建良（2019），正當防衛、比例原則與特別犧牲——刑法與憲法的思維方法與理路比較，月旦法學雜誌，291期，頁26-48。
- 李茂生（2009），風險社會與規範論的世界，月旦法學雜誌，173期，頁145-153。
- （2013），量刑因子的調查與辯論，法官協會雜誌，15卷，頁100-113。
- （2015），應報、死刑與嚴罰的心理，中研院法學期刊，17期，頁295-311。
- 周漾沂（2012），論攻擊性緊急避難之定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁403-444。
- （2016），刑罰的自我目的性——重新證立絕對刑罰理論，政大法學評論，147期，頁279-346。
- 林山田（2008），刑法通論（下冊），10版，臺北：元照。
- 林鈺雄（2017），刑事訴訟法（上冊），8版，臺北：新學林。
- 孫啟強（2019），定應執行刑逾二年可否宣告緩刑，司法周刊，1981期，2-3版。
- 許恒達（2019），累犯與處斷刑加重之裁量：評大法官釋字第775號解釋暨後續實務裁判，月旦法學雜誌，294期，頁5-32。
- 許家馨（2014），應報即復仇？——當代應報理論及其對死刑之意涵初探，中研院法學期刊，15期，頁207-282。
- 黃榮堅（2012），基礎刑法學（上冊），4版，臺北：元照。

陳冠廷(2020)，法律規範性理論的「無心」之過？——以哈特與拉茲之理論為核心的反思，中研院法學期刊，27期，頁345-406。

謝煜偉(2014)，「永山基準」台灣版？——死刑量刑基準的具體化／最高法院102台上5251判決，台灣法學雜誌，249期，頁212-218。

——(2014)，重新檢視死刑的應報意義，中研院法學期刊，15期，頁139-206。

——(2015)，寬容社會的曙光？——從市民刑法的例外、犯罪事後處理機能、社會責任於個人責任的反饋回應三篇評論文，中研院法學期刊，17期，頁369-402。

——(2018)，論「教化可能性」在死刑量刑判斷上的意義與定位：從最高法院102年度台上字第170號判決到105年度台上字第984號判決之演變，臺北大學法學論叢，105期，頁133-186。

——(2019)當弦外之音成為主旋律——評釋字第775號解釋兼論解釋公布後之量刑新趨勢，月旦法學雜誌，294期，頁33-55。

顏厥安(2014)，何謂正義？一個初步的理論說明，收於：社團法人台灣法學會編，台灣法學新課題(十)，頁1-23，臺北：元照。

——(2015)，不再修補殺人機器——評論許家馨與謝煜偉教授有關死刑之文章，中研院法學期刊，17期，頁335-368。

蘇俊雄(2000)，刑法總論III，2版，臺北：自版。

2. 外文部分

(1) 日文

淺田和茂(2007)，刑法總論，補正版，東京：成文堂。

飯島暢(2007)，最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展

- 開，香川法学，26卷3・4号，頁331-379。
- 井田良（1996），量刑理論の体系化のための覚書，法学研究，69卷2号，頁293-317。
- （2001），量刑理論と量刑事情，現代刑事法，21号，頁35-43。
- 遠藤邦彦（2011），量刑判断過程の総論的検討，收於：大阪刑事実務研究会編，量刑実務大系（第1卷）：量刑総論，頁1-204，東京：判例タイムズ社。
- 川崎一夫（1991），体系的量刑論，東京：成文堂。
- 小池信太郎（2004），量刑における消極的責任主義の再構成，慶應法学，1号，頁213-322。
- （2006），量刑における犯行均衡原理と予防的考慮（1）：日独における最近の諸見解の検討を中心として，慶應法学，6号，頁1-87。
- 佐伯仁志（2013），刑法総論の考え方・楽しみ方，東京：有斐閣。
- 城下裕二（1995），量刑基準の研究，東京：成文堂。
- （2009），消極的責任主義の帰趨——わが国における近時の量刑理論の批判的検討，收於：川端博、山口厚、井田良、浅田和茂編，理論刑法学の探究（2），頁29-60，東京：成文堂。
- （2009），量刑事情の意義と限界，收於：量刑理論の現代的課題，増補版，頁65-88，東京：成文堂。
- （2016），特別予防論の現在と責任論の展望，法律時報，88巻7号，頁15-22。
- 白取祐司（2015），刑事訴訟法，8版，東京：日本評論社。
- 中村悠人（2015），刑罰目的論と刑罰の正当化根拠論，現代法学：東京経済大学現代法学会誌，28巻，頁175-205。
- 高橋直哉（2018），刑法基礎理論の可能性，東京：成文堂。

高山佳奈子(1999), 故意と違法性の意識, 東京: 有斐閣。

団藤重光(1990), 刑法綱要総論, 3版, 東京: 創文社。

松宮孝明(2011), 量刑に対する責任、危険性および予防の意味, 収於: ヴォルフガング・フリッシュ、岡上雅美、浅田和茂編, 量刑法の基本問題——量刑理論と量刑実務との対話, 頁31-44, 東京: 成文堂。

畑山靖(2011), 被告人が自己の犯罪により自ら多大の不利益を被ったことと量刑, 収於: 大阪刑事実務研究会編, 量刑実務大系(第3巻): 一般情状等に関する諸問題, 頁216-239, 東京: 判例タイムズ社。

原田國男(2008), 量刑判断の実際, 3版, 東京: 立花書房。

樋口亮介(2017), 行為責任論を基礎にした前科の位置づけ——近時の英米法圏の学説を素材に, 収於: 高橋則夫、只木誠、田中利幸、寺崎嘉博編, 刑事法学の未来——長井圓先生古稀記念, 頁179-207, 東京: 信山社。

平野龍一(1966), 人格責任と行為責任, 収於: 刑法の基礎, 頁31-50, 東京: 東京大学出版会。

本庄武(2002), 刑罰論から見た量刑基準(2), 一橋法学, 1巻2号, 頁424-473。

武内謙治、本庄武(2019), 刑事政策学, 東京: 日本評論社。

横田信之(2011), 被害者と量刑, 収於: 大阪刑事実務研究会編, 量刑実務大系(第2巻): 犯情等に関する諸問題, 頁2-137, 東京: 判例タイムズ社。

吉岡一男(1984), 犯罪の研究と刑罰制度, 収於: 刑事制度の基本理念を求めて——拙稿とその批判の検討, 頁101-122, 東京: 成文堂。

——(1996), 刑事学, 新版, 東京: 青林書院。

——(1999), 応報刑と謙抑主義, 収於: 京都大学法学部百周年記念論文集刊行委員会編, 京都大学法学部創立百周年記念

- 論文集（第2卷），頁503-530，東京：有斐閣。
- （2008），刑事政策の展望，收於：アメリカ犯罪学と刑事政策，頁215-229，東京：成文堂。
- 李茂生（2014），台湾刑事政策の近年の動向——二極化の狭間で，一橋法学，13卷1号，頁85-108。

(2) 西文

- Ambos, Kai, R. Antony Duff, Julian Roberts, Thomas Weigend, and Alexander Heinze, eds. 2020. *Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice Vol. 1: Anglo-German Dialogues*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Baldwin, Thomas. 1999. Punishment, Communication, and Resentment. Pp. 124-133 in *Punishment and Political Theory*, edited by Matt Matravers. Oxford: Hart Publishing.
- Boonin, David. 2008. *The Problem of Punishment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brownlee, Kimberley. 2011. The Offender's Part in the Dialogue. Pp. 54-67 in *Crime, Punishment, and Responsibility: The Jurisprudence of Antony Duff*, edited by Rowan Cruft, Matthew H. Kramer and Mark R. Reiff. New York, NY: Oxford University Press.
- Burgh, Richard W. 1982. Do the Guilty Deserve Punishment?. *The Journal of Philosophy* 79:193-210.
- Cottingham, John. 1979. Varieties of Retribution. *The Philosophical Quarterly* 29:238-246.
- Dagger, Richard. 1993. Playing Fair with Punishment. *Ethics* 103:473-488.
- Davis, Lawrence H. 1972. They Deserve to Suffer. *Analysis* 32:136-140.
- Dolinko, David. 1991. Some Thoughts about Retributivism. *Ethics*

101:537-559.

- Duff, R. Antony. 1986. *Trials and Punishments*. New York, NY: Cambridge University Press.
- . 2001. *Punishment, Communication, and Community*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2003. Probation, Punishment and Restorative Justice: Should Al Turism Be Engaged in Punishment?. *Howard Journal of Criminal Justice* 42:181-197.
- . (2003), Was ist Tatproportionalität, und warum ist dieses Prinzip wichtig?, in: Frisch/von Hirsch/Albrecht (Hrsg.), *Tatproportionalität: Normative und empirische Aspekte einer tatproportionalen Strafzumessung*, Heidelberg: C. F. Müller, S. 23-46.
- . 2007. *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law*. Oxford: Hart Publishing.
- Ezorsky, Gertrude. 1972. The Ethics of Punishment. Pp. xi-xxvii in *Philosophical Perspectives on Punishment*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Fassin, Didier (2017), *Punir: une passion contemporaine*, Paris: Seuil.
- Feinberg, Joel. 1970. The Expressive Function of Punishment. Pp. 95-118 in *Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Fingarette, Herbert. 1977. Punishment and Suffering. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association* 50:499-525.
- Frase, Richard S. 2004. Limiting Retributivism. Pp. 83-120 in *The Future of Imprisonment*, edited by Michael Tonry. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2005. Punishment Purposes. *Stanford Law Review* 58:67-83.
- . 2012. Theories of Proportionality and Desert. Pp. 131-149 in

- The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*, edited by Joan Petersilia and Kevin R. Reitz. New York, NY: Oxford University Press.
- Friedman, David D., and William Sjoström. 1993. Hanged for a sheep: The Economics of Marginal Deterrence. *The Journal of Legal Studies* 22:345-366.
- Garland, David. 2001. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago, Ill.: The University of Chicago Press.
- Günther, Klaus. 2014. Criminal Law, Crime and Punishment as Communication. Pp. 123-139 in *Liberal Criminal Theory: Essays for Andreas von Hirsch*, edited by AP Simester, Antje du Bois-Pedain and Ulfrid Neumann. Oxford: Hart Publishing.
- Hampton, Jean. 1992. An Expressive Theory of Retribution. Pp.1-25 in *Retributivism and Its Critics*, edited by Wesley Cragg. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Hart, H.L.A. 1955. Are There Any Natural Rights?. *Philosophical Review* 64:175-191.
- . 2008. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. 2d ed. New York, NY: Oxford University Press.
- von Hirsch, Andrew. 1991. Proportionality in the Philosophy of Punishment: From “Why Punish?” to “How Much?”. *Israel Law Review* 25:549-580.
- . 1993. *Censure and Sanctions*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2017. *Deserved Criminal Sentences*. Oxford: Hart Publishing.
- von Hirsch, Andrew, and Andrew Ashworth. 2005. *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*. Oxford: Oxford University Press.

- Hörnle, Tatjana (2017), *Straftheorien* (2011), 2. Aufl., Heidelberg: Mohr Siebeck.
- Kant, Immanuel. 1996 (1797). *The Metaphysics of Morals: The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant: Practical Philosophy*, edited and translated by Mary J. Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kleinig, John. 1973. *Punishment and Desert*. Berlin: Springer.
- Lucas, J. R. 1980. *On Justice*. New York, NY: Clarendon Press.
- Morris, Herbert. 1968. Persons and Punishment. *The Monist* 52:475-501.
- Morris, Norval. 1982. *Madness and the Criminal Law*. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
- Narayan, Uma. 1993. Appropriate Responses and Preventive Benefits: Justifying Censure and Hard Treatment in Legal Punishment. *Oxford Journal of Legal Studies* 13:166-182.
- Nozick, Robert. 1981. *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Primoratz, Igor. 1989. Punishment as Language. *Philosophy* 64:187-205.
- Rachels, James. 1997. Punishment and Desert. Pp. 470-479 in *Ethics in Practice*, edited by Hugh LaFollette. Oxford: Basil Blackwell.
- Rawls, John. 1999. Legal Obligation and the Duty of Fair Play. Pp. 117-129 in *Collected Papers of John Rawls*, edited by Samuel Freeman. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rodriguez-Blanco, Veronica. 2014. *Law and Authority under the Guise of the Good*. Oxford: Hart Publishing.
- Roxin, Claus (1977), Strafzumessung im Lichte der Strafzwecke, in: Walder/Trechsel (Hrsg.), *Lebendiges Strafrecht: Festgabe zum 65. Geburtstag von Hans Schultz*, Bern: Stämpfli, S. 463-481.
- Ryberg, Jesper. 2004. *The Ethics of Proportionate Punishment: A Critical Investigation*. Netherland: Kluwer Academic Publishers.

- Sadurski, Wojciech. 1985. Distributive Justice and the Theory of Punishment. *Oxford Journal of Legal Studies* 5:47-59.
- . 1985. *Giving Desert Its Due: Social Justice and Legal Theory*. Netherland: Kluwer Academic Publishers.
- . 1989. Theory of Punishment, Social Justice and Liberal Neutrality. *Law and Philosophy* 7:351-373.
- Schünemann, Bernd (2002), Aporien der Straftheorie in Philosophie und Literatur, in: Prittwitz (Hrsg.), Festschrift für Klaus Lüderssen, Baden-Baden: Nomos, S. 327-343.
- Seelmann, Kurt. 2014. Does Punishment Honour the Offender?. Pp. 111-121 in *Liberal Criminal Theory: Essays for Andreas von Hirsch*, edited by AP Simester, Antje du Bois-Pedain and Ulfrid Neumann. Oxford: Hart Publishing.
- Sher, George. 1987. *Desert*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Steiker, Carol S. 1997. Punishment and Procedure: Punishment Theory and the Criminal-Civil Procedural Divide. *Georgetown Law Journal* 85:775-820.
- Sullivan, E. Thomas, and Richard S. Frase. 2008. *Proportionality Principles in American Law: Controlling Excessive Government Actions*. New York, NY: Oxford University Press.
- Tadros, Victor. 2005. *Criminal Responsibility*. Oxford: Oxford University Press.
- Walker, Nigel. 1999. Even More Varieties of Retribution. *Philosophy* 74:595-605.
- Warner, Kate. 2011. Equality before the Law: Racial and Social Background Factors as Sources of Mitigation at Sentencing. Pp. 124-145 in *Mitigation and Aggravation at Sentencing*, edited by Julian V. Roberts. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitman, James Q. 2005. *Harsh Justice: Criminal Punishment and the Widening Divide between America and Europe*. New York, NY: Oxford University Press.

Constructing the Proportionality Principle in Sentencing:

A Theoretical Attempt to Establish a Sentencing Theory
from Retributivism

*Keng-Wei Fan**

Abstract

The principle of sentencing proportionality has been widely accepted as “Let the punishment fit the crime.” However, since this concept is still ambiguous, this principle should be refined. To solve this theoretical question, the strategy adapted in this paper is to examine the substance and criterion embodied in the proportionality principle. The author believes the essence of sentencing is to determine the degree of harm imposed on convicted criminals. In the criminal justice system, this determination becomes an offender’s liability and punishment, which sentence should be commensurate with the criminal’s offense. To achieve this goal, judges should apply the proportionality principle in sentencing to determine the levels of the penalty imposed. In other words, the sentencing proportionality principle is the specific application of this principle when considering criminal responsibility. The purpose of criminal punishment itself should serve as the criterion in deciding the proportionality of the imposed punishment. In the same vein, the above arguments on the proportionality principle in sentencing have a strong linkage to the long-standing debate between retributivism and utilitarianism. More specifically, the articulated basis of contemporary theories on the proportionality principle is derived from either retributivism or utilitarianism or both. In short, this paper first analyzes

* Assistant Professor, Department of Law, National Dong Hwa University.

the concepts of each important retribution theory with emphasis on their advantages and disadvantages when applied to constructing sentencing proportionality. Then, in conclusion, this paper proposes a “pay for crime” theory, which aligns with the concept of the retribution theory, as a basis to reconstruct the scheme of the sentencing proportionality principle.

KEYWORDS: punishment philosophy, sentencing theory, proportionality principle, retributivism, utilitarianism, hard treatment, simple desert theory, fair play theory, Hybrid Proportionality theory, communicative retributivism.